Landgericht Düsseldorf, 4b O 91/18

Datum:	18.06.2020
Gericht:	Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper:	4b. Zivilkammer
Entscheidungsart:	Urteil
Aktenzeichen:	4b O 91/18
ECLI:	ECLI:DE:LGD:2020:0618.4B.O91.18.00

Tenor:

I. Die Beklagten werden verurteilt,

1. der Klägerin in geordneter Aufstellung in elektronischer Form darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Beklagten, X XXXX

wobei nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen,

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland angeboten und/oder an solche geliefert haben;

b) Codiereinrichtungen zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen und insbesondere mobile Endgeräte, die eine solche Codiereinrichtung enthalten, die derart eingerichtet ist, dass die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist, die Formatkennungs-Bits im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zur Verfügung stehende Formatkennungs-Stellen abgebildet werden, welche größer als die Anzahl der Formatkennungs-Bits ist, dass nach einem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits wiederholt abgebildet werden, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen,

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten, in den Verkehr gebracht oder gebraucht oder zu den genannten Zwecken eingeführt oder besessen haben;

und zwar unter Angabe

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden,

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Daten außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

2. der Klägerin in elektronischer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX die zu I. 1. a) und b) bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, ?zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, ?zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und die Anschriften der Empfänger,

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die jeweilige Beklagte dessen Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist,

und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen;

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziff. I. 1. a) und b) bezeichneten, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Im Übrigen wird die Klage, soweit sie sich auf XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

abgebildet werden, welche größer als die Anzahl der Formatkennungs-Bits ist, wobei nach einem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits wiederholt abgebildet werden, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen,

dadurch gekennzeichnet, 9

dass nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen. 10

und 11

6. Codiereinrichtung zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen, die derart eingerichtet ist, dass die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist, 12

die Formatkennungs-Bits im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zur Verfügung stehende Formatkennungs-Stellen abgebildet werden, welche größer als die Anzahl der Formatkennungs-Bits ist, 13

dass nach einem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits wiederholt abgebildet werden, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen, 14

dadurch gekennzeichnet, 15

dass nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen. 16

Die Klägerin räumte der XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX eine weltweite, persönliche, nicht übertragbare, nicht exklusive und unwiderrufliche Lizenz zur Verwendung des geistigen Eigentums der Klägerin ein, um in dem Vertrag näher definierte Produkte, darunter XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Klägerin ihren Lizenznehmern, darunter auch die Muttergesellschaft der Beklagten, mit Schreiben vom XXXXXXXX mit (Anlage KAP20/KAP20a)

Die Beklagten gehören zu dem in XXXXXXXXXXXXXXXX ansässigen XXX-Konzern, der sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Haushalts- und Unterhaltungselektronik, darunter auch Mobiltelefone, beschäftigt. Die Sparte für Mobiltelefone ist dabei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX zugeordnet. XXX hält unter anderem eine Lizenz an der Marke Alcatel, unter der sie Mobiltelefone vertreibt. 19

Bei der Beklagten zu 1) handelt es sich um die deutsche Vertriebsgesellschaft von XXX. Sie ist für das Marketing und den Verkauf der Mobiltelefone in der Bundesrepublik Deutschland verantwortlich. Sie ist Ansprechpartner für Verkäufe und die Belieferung großer Abnehmer. Außerdem stellt sie den Kundenservice für die Geräte zur Verfügung. 20

Die Beklagte zu 2) ist für den Vertrieb der Mobiltelefone in Europa zuständig. Sie betreibt die Website XXXXXXXXXXXXXXXXX, über die die Mobiltelefone vermarktet werden. Die Inhalte der Website sind unter anderem in deutscher Sprache abrufbar. Wegen der Einzelheiten des Internetauftritts wird auf die Anlagen KAP 3 und 4 Bezug genommen. 21

Auf der Internetseite der Beklagten zu 2) werden unter anderem folgende Modelle unter der Marke XXXXXXXXX beworben bzw. in der Bundesrepublik Deutschland veräußert: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX (Anlagen KAP 8 und KAP 23). Diese Geräte entsprechen wie alle Mobiltelefone der Beklagten den Anforderungen des UMTS-Standards, sind also UMTS-fähig. Mit der Klage wendet sich die Klägerin gegen alle UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten (angegriffene Ausführungsform). 22

Bei UMTS handelt es sich um einen Mobilfunkstandard. Dieser sieht für die Datenübertragung im Uplink unter anderem einen komprimierten Modus („Compressed Mode“) vor, der in den technischen Spezifikationen 3GPP TS 25.211 (Anlage KAP 9) und 3GPP TS 25.212 (Anlage KAP 10) näher beschrieben wird. 23

Im normalen Modus werden in jedem Rahmen 15 Zeitschlitze übertragen. Im Compressed Mode ist die Anzahl der Zeitschlitze geringer, so dass eine Übertragungslücke von der Länge TGL („Transmission Gap Length“) entsteht. Es ergibt sich folgende Rahmenstruktur (vgl. Ziff. 4.4.1 der 3GPP TS 25.212). 24

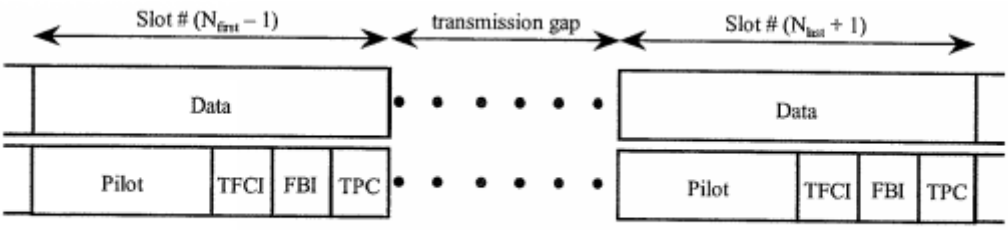

Figure 12: Frame structure in uplink compressed transmission 25

Verschiedene Rahmen- und Zeitschlitzformate gemäß UMTS sind nachstehend tabellarisch wiedergegeben (vgl. Tab. 2 der 3GPP TS 25.211). 26

27

Slot Form at #i	Channel Bit Rate (kbps)	Channel Symbol Rate (ksps)	SF	Bits/ Frame	Bits/ Slot	N_{pilot}	N_{TPC}	N_{TFCI}	N_{FBI}	Transmitted slots per radio frame
0	15	15	256	150	10	6	2	2	0	15
0A	15	15	256	150	10	5	2	3	0	10-14
0B	15	15	256	150	10	4	2	4	0	8-9
1	15	15	256	150	10	8	2	0	0	8-15
2	15	15	256	150	10	5	2	2	1	15
2A	15	15	256	150	10	4	2	3	1	10-14
2B	15	15	256	150	10	3	2	4	1	8-9
3	15	15	256	150	10	7	2	0	1	8-15
4	15	15	256	150	10	6	4	0	0	8-15

In der rechten Spalte der Tabelle ist die Anzahl an Zeitschlitzen angegeben, die pro Rahmen übertragen wird. N_{TFCI} gibt die Anzahl der TFCI-Bits pro Zeitschlitz an. Der TFCI („Transport Format Combination Indicator“) hat eine Länge von 32 Bits. Im Compressed Mode gibt es Konstellationen, in denen in Abhängigkeit von der Anzahl der Zeitschlitze pro Rahmen und der pro Zeitschlitz vorgesehenen N_{TFCI} mehr als 32 Stellen für TFCI-Bits in einem Rahmen zur Verfügung stehen. Wie die TFCI-Bits im Einzelnen auf die zur Verfügung stehenden Stellen in einem Rahmen verteilt werden sollen, ergibt sich aus dem Abschnitt 4.3.5.2 der 3GPP 25.212, der sich mitdem Mapping des TFCI im komprimierten Modus beschäftigt. Demnach werden die TFCI-Bits, die der Übertragungslücke folgen, nach Maßgabe von Ziffer 4.3.5.2.1 der 3GPP 25.212 in den überzähligen Stellen für TFCI-Bits erneut abgebildet. 28

4.3.5.2.1 Uplink compressed mode 29

For uplink compressed mode, the slot format is changed so that no TFCI coded bits are lost. The different slot formats in compressed mode do not match the exact number of TFCI coded bits for all possible TGLs. Repetition of the TFCI bits is therefore used.

Denote the number of bits available in the TFCI fields of one compressed radio frame by D and the number of bits in the TFCI field in a slot by N_{TFCI}. The parameter E is used to determine the number of the first TFCI bit to be repeated.

$E = N_{first} N_{TFCI}$, if the start of the transmission gap is allocated to the current frame. 30
$E = 0$, if the start of the transmission gap is allocated to the previous frame and the end of the transmission gap is allocated to the current frame.

The TFCI coded bits b_k are mapped to the bits in the TFCI fields d_k. The following relations define the mapping for each compressed frame.

$$d_k = b_k$$

where $k = 0, 1, 2, \ldots, \min(31, D\text{-}1)$.

If $D > 32$, the remaining positions are filled by repetition (in reversed order):

$$d_{D-k-1} = b_{(E+k) \bmod 32}$$

where $k = 0, \ldots, D\text{-}33$.

Wegen der Einzelheiten der technischen Spezifikationen 3GPP TS 25.211 und 3GPP TS 25.212 wird auf die Anlagen KAP 9 und KAP 10 Bezug genommen. 31

UMTS-fähige Mobiltelefone können die nach dem Standard zwingend vorgeschriebenen Messungen neben der Nutzung des Compressed Mode auch dadurch erfüllen, dass sie mit einem zweiten Receiver ausgestattet sind, der zur Durchführung der Messungen technisch hergerichtet ist. Diese technische Alternative erfährt jedoch bisher auf dem Markt keine Umsetzung, vielmehr bieten die Hersteller der für die Mobilfunkgeräte benötigten Chips ausschließlich Chipsätze an, die zur Durchführung der Messungen den UMTS-Compressed Mode zur Anwendung bringen. 32

Der Konzern der Beklagten übernahm im Jahr 2004 einen Teil und später das gesamte Mobiltelefongeschäft des Unternehmens XXXXX (nachfolgend: XXXXXXXXXX 33

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX. Im Zuge dessen räumte XXXX der XXXXXXXXX (nachfolgend **XXX**) und deren Tochtergesellschaften – den Beklagten – eine (Unter-)Lizenz an allen Patenten ein, an denen XXXX aufgrund bestehender Patentlizenzaustauschverträge eine (Unter-)Lizenz einräumen konnte. Bei der XXX handelte es sich um ein vonXXXX und der XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX gehaltenen Gesellschaft, wobei die Beteiligung von XXXX nur XX % betrug. Wegen der Einzelheiten des Vertrages zwischen XXXX und XXX wird auf die Anlage B 2 Bezug genommen.

Unter dem XXXXXXXXXXX schlossen die Klägerin und die XXXXXXXXXXXXXXX ein XXXXXXXXXXXXX. Ergänzt wurde die Vereinbarung durch ein erstes und zweites Amendment vom XXXXXXXX und vom XXXXXXXX sowie XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. In letzterem wurden XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX. 34

Am 03.08.2011 wies die Klägerin die Muttergesellschaft der Beklagten auf die Notwendigkeit einer Lizenznahme an Patenten, die eine für den UMTS-Standard erforderliche Technologie beinhalten, hin, worauf die Muttergesellschaft ihre grundsätzliche Bereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags bekundete. 35

Im August 2016 übersandte die Klägerin der Muttergesellschaft als Verhandlungsführerin für den XXX-Konzern die als Anlage F8/1 (deutsche Übersetzung: Anlage F8/1a) vorgelegte mit *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX* überschriebene Aufstellung über mögliche Inhalte eines Lizenzvertrags. Darin sind insbesondere die lizenzierten Standards „W-CDMA“ und „LTE“, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX genannt. Die Aufstellung enthielt auch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Wegen des genauen Inhalts des XXXXXXX wird auf diesen Bezug genommen. 36

Dem XXXXXXX war des Weiteren eine Seite über die *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX* beigefügt. Darin bezog sich die Klägerin XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX und fügte die in dem hiesigen Verfahren als Anlage F8/2 (deutsche Übersetzung: Anlage F8/2a) vorgelegten Informationen, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, bei, auf die wegen ihres genaueren Inhalts verwiesen wird. Angaben zu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX erfolgten im Zusammenhang mit der Zusendung des XXXXXXXX nicht. 37

Die Muttergesellschaft reagierte auf die Zusendung des XXXXXXXX mit E-Mail vom 17.10.2016 (Anlage B10), wobei sie einer Lizenzierung entsprechend des XXXXXX XXXX aus in der E-Mail näher dargelegten Gründen, widersprach. 38

Am 22.12.2017 ließ die Klägerin der Muttergesellschaft ein Schreiben mit Vertragsunterlagen für den Abschluss eines Portfoliolizenzvertrags über ihre XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Patente (Anschreiben vorgelegt als Anlage F9/1; deutsche Übersetzung: Anlage F9/1a; Vertragsentwurf „Exhibit F“ zu dem Anschreiben vorgelegt als Anlage F9/7; deutsche Übersetzung: Anlage F9/7a) zukommen. Dieses sah im Adressfeld der Vertragsunterlagen einen von der Muttergesellschaft abweichenden Adressaten vor, weshalb die Klägerin die Vertragsunterlagen am 12.02.2018 ein weiteres Mal an die 39

Muttergesellschaft versandte (Anlage B4; deutsche Übersetzung: Anlage B4a). Nachfolgend werden die dargestellten Handlungen aus Dezember 2017 und Februar 2018 zusammenfassend als „Angebot aus Februar 2018“ bezeichnet.

Dem Schreiben war unter anderem eine Gebührentabelle aus dem XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX („Exhibit E“ zu dem Anschreiben vom 22.12.2017, vorgelegt als Anlage F9/6; deutsche Übersetzung: Anlage F9/6a bzw. Teil des als Anlage B4/ B4a vorgelegten Dokuments, dort bezeichnet als Anlage 1 zu dem Vertragsentwurf) beigefügt. Diese sah XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 40

[redacted] 41

Zu den XXXXXXXXXXXXXXXXXX heißt es in der Anlage (nachfolgend auch: Anlage 1) zudem: 42

„XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX wurden im Rahmen der außergerichtlichen Vertragsverhandlungen auch erläutert, wobei die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Wegen der Vertragsinhalte wird auf die vorgelegten Dokumente verwiesen.

Die Klägerin ist der Ansicht, Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagten stellten eine unmittelbare Verletzung von Anspruch 6 und eine mittelbare Verletzung von Anspruch 1 des Klagepatents dar. Die angegriffene Ausführungsform verwende den im UMTS-Standard vorgesehenen Compressed Mode im Uplink. Etwas anderes behaupteten auch die Beklagten nicht. Untersuchungen einzelner Modelle der angegriffenen Ausführungsform, nämlich XXXXXXX und XXX, hätten dies sogar belegt. Selbst das Modell XXXXxxXXXXXX, das einen zweiten RF-Receiver aufweise, verwende im Uplink den Compressed Mode nach dem UMTS-Standard. Dies führe aber zwangsläufig dazu, dass sämtliche Merkmale der Klagepatentansprüche verwirklicht würden. Es sei unschädlich, dass es sich bei dem ersten Bit, das nach dem UMTS-Standard im Compressed Mode der Übertragungslücke folge, nicht um ein TFCI-Bit handele. Soweit die Klagepatentansprüche verlangten, die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits wiederholt abzubilden, seien damit die ersten TFCI-Bitsgemeint, die nach der Übertragungslücke abgebildet seien. Damit werde nicht ausgeschlossen, dass sich zwischen der Übertragungslücke und den ersten TFCI-Bits noch andere Daten wie das Pilotsignal befänden. 55

Die Klägerin ist der Auffassung, die Rechte aus dem Klagepatent seien hinsichtlich der angegriffenen Ausführungsform, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX, nicht XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX erschöpft. Weder gebe es eine weltweite Erschöpfung, noch eine Erschöpfung von Verfahrensansprüchen. Im Übrigen seien die Voraussetzungen für eine Erschöpfung seitens der Beklagten nicht dargelegt. So XXXX alle von ihr – der Klägerin – untersuchten Mobilgeräte der Beklagten XXXXXXXXXXXXXX. Jedenfalls habe XXXXX seit dem XXXXXXXX keine Rechte mehr an Schutzrechten der Klägerin XXXXX. Die Klägerin behauptet, die Beklagten würden ausschließlich XXXXXX produzieren. 56

Die Klägerin ist der Ansicht, ihr stünden die geltend gemachten Ansprüche auch im Hinblick auf die Standardessentialität des Klagepatents zu. 57

Unbeschadet dessen, dass sie schon eine marktbeherrschende Stellung nicht innehabe, habe sie eine solche auch nicht durch Geltendmachung der auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung gerichteten Ansprüche missbräuchlich ausgenutzt. Sie habe sich insbesondere FRAND-konform im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH verhalten. 58

Den Beklagten seien sowohl durch das Schreiben aus August 2016 (Anlage F8) als auch durch die Zusendung der Vertragsunterlagen am 12.02.2018 (Anlagenkonvolut F9 bzw. Anlage B4) FRAND-gemäße Angebote unterbreitet worden. 59

Das XXXXXX aus August 2016 erfülle die Anforderungen der EuGH-Rechtsprechung. Insbesondere sei darin durch die Bezugnahme auf die Lizenzgebühren, die sich für die Beklagte nach XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ergeben würden, hinreichend zur Angemessenheit und zu Vergleichsverträgen ausgeführt worden. 60

Im Zusammenhang mit dem Vertragsentwurf aus Februar 2018 behauptet die Klägerin, ausgehend von den zu Vergleichszwecken vorgelegten Vergleichsverträgen XXXXXXXXXXXXX ergebe sich eine diskriminierungsfreie Lizenzierungsspanne von XXXXXXXXXXXXXXXX. Da das Lizenzangebot der Klägerin in diesen Korridor fällt, erweise 61

es sich als diskriminierungsfrei. Es fehle aber selbst dann, wenn von einer Diskriminierung der Beklagten auszugehen sei, an einer spürbaren Beeinträchtigung der Position der Beklagten im Wettbewerb.

Der Inhalt des im Februar 2018 vorgeschlagenen Entwurfs erweise sich auch im Übrigen als angemessen. 62

Insbesondere trage Ziffer 4.6 des Vertragsentwurfs XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX hinreichend Rechnung. Eine XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sei nicht erforderlich, weil dies bereits bei der Bemessung der Lizenzgebühren berücksichtigt worden sei. Die in Ziffer 10.4 vorgesehene XXXXXXXXXX entspreche der Branchenüblichkeit. Die XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX betreffe die Frage der Standardessentialität oder des Rechtsbestands der Portfoliopatente nicht. 63

Schließlich ist die Klägerin der Auffassung, dass die Muttergesellschaft jedenfalls zur Abgabe eines Gegenangebots verpflichtet gewesen sei, nachdem ihr XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX. Die Tatsache, dass sie ein solches nicht vorgelegt hat, sowie ihr zögerliches Verhalten im Übrigen, insbesondere im Zusammenhang mit der Unterzeichnung eines Geheimhaltungsabkommens zu prozessualen Zwecken, zeige ihre Lizenzunwilligkeit. 64

Die von den Beklagten erhobene Einrede der Verjährung greife nicht durch, da die Verjährungsfrist seit dem Jahr 2011 wegen schwebender Vergleichsverhandlungen gehemmt gewesen sei. Dies gelte auch für die Zeit nach Oktober 2016, weil die Klägerin noch im Dezember 2017 ein Lizenzangebot unterbreitet habe.Zunächst hat die Klägerin Klageanträge angekündigt, nach denen Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung, Rückruf und die Feststellung der Schadensersatzpflicht für die Zeit seit dem Jahr 2004 (Beklagte zu 2)) bzw. 2007 (Beklagte zu 1)) geltend gemacht wurden. Zudem hat sie auch hinsichtlich der Beklagten zu 2) einen Antrag auf Vernichtung patentverletzender Erzeugnisse angekündigt. 65

Nachdem sie die Klage teilweise zurückgenommen hat, beantragt die Klägerin nunmehr noch, 66

I. die Beklagten zu verurteilen, 67

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, 68

zu unterlassen, 69

mobile Endgeräte, geeignet zur Durchführung eines Verfahrens zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen, 70

wobei die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist, 71

72

wobei die Formatkennungs-Bits im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zur Verfügung stehende Formatkennungs-Stellen abgebildet werden, welche größer als die Anzahl der Formatkennungs-Bits ist, wobei nach einem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits wiederholt abgebildet werden, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen,

wobei nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen, 73

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern; 74

2. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Fall wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an dem gesetzlichen Vertreter der Beklagten zu vollziehen ist, 75

zu unterlassen 76

Codiereinrichtungen zum Abbilden von Formatkennungs-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen und insbesondere mobile Endgeräte, die eine solche Codiereinrichtung enthalten, die derart eingerichtet ist, dass die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist, die Formatkennungs-Bits im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zur Verfügung stehende Formatkennungs-Stellen abgebildet werden, welche größer als die Anzahl der Formatkennungs-Bits ist, dass nach einem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits wiederholtabgebildet werden, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem ersten Abbilden der Formatkennungs-Bits die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungs-Bits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungs-Bit zu belegen, 77

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen; 78

3. der Klägerin in geordneter Aufstellung in elektronischer Form darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie, die Beklagten, seit dem 01.01.2014 die zu I. 1. und I. 2. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe 79

a) der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer der Erzeugnisse 80

81

b) der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer und Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der Menge der ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Preise, die für die betreffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, 82

wobei zum Nachweis der Angaben die entsprechenden Kaufbelege (nämlich Rechnungen, hilfsweise Lieferscheine) in Kopie vorzulegen sind, wobei geheimhaltungsbedürftige Daten außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen; 83

4. der Klägerin in elektronischer Form darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagten seit dem 01.01.2014 die zu I. 1. und I. 2. bezeichneten Handlungen begangen haben, und zwar unter Angabe 84

a) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, ?zeiten und -preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, 85

b) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, ?zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger, 86

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeiträume, und bei direkter Werbung, wie Rundbriefen, den Namen und die Anschriften der Empfänger, 87

d) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns, 88

wobei den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die jeweilige Beklagte dessen Kosten trägt und ihn zugleich ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist, 89

und geheimhaltungsbedürftige Details außerhalb der auskunftspflichtigen Daten geschwärzt werden dürfen; 90

5. die unter Ziff. I. 2. bezeichneten, seit dem 01.01.2014 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen und die erfolgreich zurückgerufenen Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen; 91

6. <u>nur die Beklagte zu 1):</u> die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder ihrem Eigentum befindlichen, unter Ziff. I. 2. bezeichneten Erzeugnisse auf eigene Kosten zu vernichten oder nach ihrer Wahl an einen von der Klägerin zu benennenden oder zu beauftragenden Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der jeweiligen Beklagten herauszugeben; 92

93

II. festzustellen, dass die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziff. I. 1. und I. 2. bezeichneten, seit dem 01.01.2014 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Beklagte beantragt, 94

die Klage abzuweisen, 95

hilfsweise den Rechtsstreit bis zu einer Entscheidung des Bundespatentgerichts über die gegen den deutschen Teil des EP XXXXXXXX B1 eingereichte Nichtigkeitsklage auszusetzen, 96

hilfsweise ihr nachzulassen, die Zwangsvollstreckung gegen Sicherheitsleistung (Bank- oder Sparkassenbürgschaft) abzuwenden. 97

Die Beklagten sind der Ansicht, die Klägerin habe eine Verletzung des Klagepatents nicht schlüssig dargelegt. Der Compressed Mode nach dem UMTS-Standard müsse bei der Implementierung des Standards nicht zwingend verwendet werden. Zwar müssten Mobiltelefone in der Lage sein, Frequenz- und Inter-RAT-Messungen vorzunehmen. Dies müsse aber nicht zwingend in der mit dem Compressed Mode erzeugten Übertragungslücke erfolgen, sondern könne auch mittels eines zweiten RF-Receivers geschehen. Durch die – bestrittenen – Tests der Klägerin mit bestimmten Modellen der angegriffenen Ausführungsform scheine die Klägerin die Klage nunmehr auf diese Modelle beschränken zu wollen. Ungeachtet dessen sehe der UMTS-Standard für den Compressed Mode vor, dass auf die Übertragungslücke zunächst ein Pilotsignal und dann die TFCI-Bits folgten. Damit fehle es an einer Verletzung des Klagepatents, weil das Pilotsignal nicht wiederholt abgebildet werde und die wiederholt abgebildeten TFCI-Bits nicht – wie vom Klagepatent verlangt – unmittelbar der Übertragungslücke folgten. 98

Die Beklagten sind weiter der Auffassung, die Klägerin könne infolge des Grundsatzes der Erschöpfung keine Rechte aus dem Klagepatent hinsichtlich solcher Modelle der angegriffenen Ausführungsform geltend machen, die XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX und in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben würden. Durch die XXXXXXXXXXXXXXXXX habe die Klägerin die Zustimmung erteilt, dass die XXXXXXXXXXXXX Produkte XXXXXXXXXXXX auch in der EU vertreiben dürfen. Die Lizenzvereinbarung enthalte XXXXXXXX, so dass die Klägerin das Klagepatent nach dem geltenden XXXXXXxX Recht nicht mehr gegen die XXXXXXXXXXXXX geltend machen könne. Dies bestätige auch eine von den Beklagten eingeholte gutachterliche Stellungnahme zum XXXXXX Recht und gelte sogar für die Zeit nach der Änderungsvereinbarung. Abgesehen davon behaupten die Beklagten, dass Modelle der angegriffenen Ausführungsform auch in Indien hergestellt würden. 99

Weiterhin seien die Beklagten aufgrund der von XXXXX gegenüber XXX gewährten (Unter-)Lizenz zur Nutzung der Lehre des Klagepatents berechtigt, da zu den lizenzierten Patenten auch das Klagepatent gehört habe. Eine weitere Berechtigung ergebe sich aus dem XXXXXXXXXX zum XXXXXXXXXXXX zwischen der Klägerin und der XXXXXXXXXX. 100

Die Beklagten erheben den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand. 101

Die Beklagten behaupten, die Klägerin habe eine marktbeherrschende Stellung auf dem hier relevanten Lizenzvergabemarkt für die Technologie, die nach den streitgegenständlichen UMTS-Spezifikationen zur Umsetzung des UMTS-Standards erforderlich ist, sowie auf dem 102

nachgelagerten Produktmarkt für UMTS-fähige Mobiltelefone, inne.

Diese ergebe sich insbesondere daraus, dass der Compressed Mode jedenfalls bei Mobiltelefonen im mittleren und unteren Preissegment zur Anwendung gelangen müsse. Die technische Implementierung eines zweiten Receivers zur Durchführung der Messungen gestalte sich – was die Klägerin mit Nichtwissen bestreitet – für Mobiltelefone im mittleren und unteren Preissegment als zu kostenintensiv. Diese müssten deshalb – um wettbewerbsfähig zu sein – den UMTS-Compressed-Mode nutzen. Dabei mache der Markt für Smartphones im mittleren und unteren Preissegment einen Marktanteil von rund 78 % aus. 103

Die Beklagten sind weiter der Auffassung, die Klägerin habe ihrer Muttergesellschaft bisher kein annahmefähiges, FRAND-Bedingungen entsprechendes Angebot unterbreitet. 104

Das Schreiben aus August 2016 weise schon die für ein FRAND-gemäßes Angebot notwendige Regelungsdichte nicht auf. Des Weiteren fehle es an der FRAND-Gemäßheit auch deshalb, weil Angaben zu bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen fehlen. 105

Das Angebot aus Februar 2018 stelle sich im Vergleich zu den in den Lizenzverträgen XXXXXXXXXXXXX getroffenen Gebührenregelungen als diskriminierend dar. 106

Ausgehend von den bei Einsichtnahme in die Verträge XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX sei davon auszugehen, dass die sich bei Umrechnung der den Firmen XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Die Unangemessenheit folge weiter auch daraus, dass die Anzahl der tatsächlich standardessentiellen Patente unklar sei, und dass das XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX veräußerten Produkte des XXX Konzerns nicht berücksichtige.

Die Beklagten erheben die Einrede der Verjährung. Aus den Verträgen mit XXXXX XXXXXXXXXX ergebe sich, dass der Klägerin die Benutzung des UMTS- und LTE-Standards durch die Beklagten jedenfalls seit 2013 bekannt gewesen sei. Soweit sich die Klägerin auf einen Hemmungstatbestand wegen schwebender Vergleichsverhandlungen berufe, hätten diese Verhandlungen frühestens Mitte 2015 begonnen und seien jedenfalls von Oktober 2016 bis Februar 2018 unterbrochen gewesen. 113

Schließlich halten die Beklagten für den Fall der Verurteilung zur Unterlassung eine Vollstreckungssicherheit in Höhe von mindestens 10.000.000,00 EUR für erforderlich, um mögliche Vollstreckungsschäden hinreichend zu sichern. 114

Entscheidungsgründe 115

Die Klage ist zulässig, aber nur teilweise begründet. 116

A 117

Die Klage ist zulässig. 118

Die Klage ist hinreichend bestimmt im Sinne von § 253 Abs. 2 ZPO. Insbesondere hat die Klägerin den Gegenstand und den Grund des erhobenen Anspruchs im Sinne der Nr. 2 der Regelung angegeben. 119

Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmen, zusammen mit dem Antrag, den Streitgegenstand. Dabei meint der Gegenstand nicht das gegenständliche Objekt der Klage und unter Grund ist nicht die rechtliche Anspruchsgrundlage zu verstehen, gemeint ist vielmehr der Sachverhalt, aus dem der Kläger den Klageanspruch herleitet (Zöller/Greger, ZPO 33. Aufl.: § 253 Rn 10). Der Streitgegenstand einer Patentverletzungsklage wird regelmäßig im Wesentlichen durch die üblicherweise als angegriffene Ausführungsform bezeichnete tatsächliche Ausgestaltung eines bestimmten Produkts im Hinblick auf die Merkmale des geltend gemachten Patentanspruchs und die darauf bezogenen Handlungen des Beklagten, die einen der Tatbestände der §§ 9, 10 PatG ausfüllen sollen (BGH GRUR 2012, 485 – Rohrreinigungsdüse II), bestimmt. Der Sachverhalt ist so konkret darzulegen, dass er den Anspruch individualisiert, das heißt von anderen Ansprüchen abgrenzt (Zöller/Greger, ZPO 33. Aufl.: § 253 Rn 11). 120

Diesen Anforderungen wird die Klage gerecht. Das gilt auch für die Angabe der angegriffenen Ausführungsform. Die Klägerin hat mit der Klage ausdrücklich alle UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten angegriffen. Soweit die Beklagten mutmaßen, die Klägerin habe die Klage später auf die Mobiltelefone beschränkt, für die sie anhand von Untersuchungen die Anwendung des „Compressed Mode“ bzw. die Verwendung von XXXXXXXXXX statt XXXXXXXXXX tatsächlich nachgewiesen habe, hat es eine solche Einschränkung nicht gegeben. Die Klägerin hat vielmehr nachfolgend und zuletzt in der mündlichen Verhandlung noch einmal klargestellt, mit der Klage alle UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten anzugreifen. 121

B 122

Die Klage ist nur teilweise begründet. 123

Die Klägerin hat gegen die Beklagten Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung sowie Schadenersatz dem Grunde nach aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 2, 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB. Die angegriffene Ausführungsform macht von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform durch die Beklagten erfolgten unberechtigt und begründen die genannten Ansprüche. Da jedoch der Einwand der Erschöpfung teilweise und der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im vollen Umfang durchgreifen, sind die Rechtsfolgen zeitlich und inhaltlich beschränkt. Ansprüche auf Unterlassung, Rückruf und Vernichtung aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. §§ 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 und 3 PatG bestehen gar nicht. 124

I. 125

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abbilden von Formatkennungsbits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen und die entsprechende Codiereinrichtung. 126

Die Priorität des Klagepatents stammt aus einer Zeit, als der UMTS-Mobilfunkstandard („Universal Mobile Telecommunication System“) entwickelt wurde. Dazu führt die Klagepatentschrift aus, dass über einen Mobilfunkkanal zu übertragende Informationen üblicherweise in Form einer vordefinierten Rahmen- und Zeitschlitzstruktur übertragen würden. Ein UMTS-Rahmen umfasse beispielsweise 15 Zeitschlitze, wobei jeder Rahmen neben den eigentlichen Daten auch bestimmte Systeminformationen beinhalte. Diese Systeminformationen umfassten insbesondere eine bekannte Pilotbitfolge oder Trainingssequenz, die von dem jeweiligen Empfänger zur Schätzung der Kanalimpulsantwort des jeweiligen Mobilfunkkanals verwendet werden könne, eine Leistungsregelungsinformation in Form eines oder mehrerer TPC-Bits („Transmit Power Control“), durch deren Inhalt die Sendeleistung des jeweiligen Empfängers gesteuert werden, sowie eine Formatkennungsinformation in Form von sogenannten TFCI-Bits („Transport Format Combination Indicator“). 127

Gemäß dem damaligen Stand der UMTS-Standardisierung (3G TS 25.212 V3.0.0. von Oktober 1999) – so die Klagepatentschrift weiter – sei für jeden UMTS-Rahmen ein TFCI-Codewort mit einer Länge von 30 TFCI-Bits vorgesehen, die gleichmäßig auf die einzelnen Zeitschlitze des UMTS-Rahmens – also zwei TFCI-Bits pro Zeitschlitz – verteilt würden. 128

Der UMTS-Standard sehe neben einer normalen Übertragung der Informationen in unkomprimierter Form auch einen komprimierten Modus („compressed mode“) für die Datenübertragung vor, um so eine Übertragungslücke künstlich zu erzeugen, während deren Dauer die Abwesenheit von gesendeten Informationen beispielsweise für Zwischenfrequenzmessungen genutzt werden könne. Im „Compressed Mode“ müssten – so die Klagepatentschrift – noch mindestens acht Zeitschlitze für die Informationsübertragung übrig bleiben. Demzufolge müssten die 30 TFCI-Bits auf die verbleibenden Zeitschlitze verteilt werden. Dafür wird das Zeitschlitzformat des jeweiligen Kanals angepasst. Da pro Rahmen ein einheitliches Zeitschlitzformat angestrebt sei, könnten jedoch Fälle auftreten, bei denen pro Rahmen mehr TFCI-Stellen zur Verfügung stehen als eigentlich für die 30 TFCI-Bits benötigt werden. 129

Im Stand der Technik sei daher für den Uplink vorgeschlagen worden, ausgewählte TFCI-Bits im „Compressed Mode“ zu wiederholen, um die überschüssigen TFCI-Stellen aufzufüllen, wobei insbesondere die unmittelbar nach der Übertragungslücke gesendeten Bits an freien TFCI-Stellen wiederholt werden sollten, um die Wiederholung möglichst effektiv zu machen. Grund dafür ist der Umstand, dass die Sendeleistungsregelung unmittelbar nach der Übertragungslücke sehr unsicher ist, so dass unmittelbar nach der Übertragungslücke die 130

Wahrscheinlichkeit für eine gestörte Übertragung am größten ist und daher diese Bits nach Möglichkeit wiederholt werden sollten. Für den Downlink sei hingegen vorgeschlagen worden, im „Compressed Mode“ die freien und überschüssigen TFCI-Stellen mit so genannten DTX-Bits („Discontinous Transmission Bits“), also Bits mit der Energie Null und damit mit einer Sendepause aufzufüllen.

Davon ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe (das technische Problem) zugrunde, ein Verfahren zum Abbilden von TFCI-Bits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen vorzuschlagen, womit ohne zusätzlichen Aufwand die Übertragungsleistung und Übertragungssicherheit verbessert werden kann. 131

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent ein Verfahren und eine Codiereinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw. 6 vor, die nachstehend in gegliederter Form wiedergegeben sind. 132

1.1 Verfahren zum Abbilden von Formatkennungsbits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen; 133

1.2 die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen werden derart zeitlich komprimiert gesendet, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist; 134

1.3 die Formatkennungsbits werden im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zur Verfügung stehenden Formatkennungs-Stellen abgebildet, welche größer als die Anzahl der Formatkennungsbits ist; 135

1.4 nach einem ersten Abbilden der Formatkennungsbits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen werden die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits wiederholt abgebildet, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungsbit zu belegen; 136

1.5 nach dem ersten Abbilden der Formatkennungsbits werden die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungsbit zu belegen 137

und 138

6.1 Codiereinrichtung zum Abbilden von Formatkennungsbits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen; 139

6.2 die Codiereinrichtung ist derart eingerichtet, dass die innerhalb eines im Komprimiermodus zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist; 140

6.3 die Formatkennungsbits werden im Komprimiermodus auf eine bestimmte Anzahl an in dem entsprechenden komprimierten Rahmen zurVerfügung stehenden Formatkennungs-Stellen abgebildet, welche größer als die Anzahl der Formatkennungsbits ist; 141

142

6.4 nach einem ersten Abbilden der Formatkennungsbits auf entsprechende Formatkennungs-Stellen werden die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits wiederholt abgebildet, um sämtliche Formatkennungs-Stellen mit einem Formatkennungsbit zu belegen;

6.5 nach dem ersten Abbilden der Formatkennungsbits werden die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungsbit zu belegen. 143

Der Vorteil der Erfindung liegt laut Klagepatentschrift darin, dass davon ausgegangen werden könne, dass die TFCI-Bits, welche nach der Übertragungslücke gesendet werden, mit zunehmendem Abstand zu der Übertragungslücke eine geringere Bitfehlerrate aufweisen, so dass es besser sei, diejenigen TFCI-Bits, welche aufgrund ihrer Nähe zu der Übertragungslücke die größte Bitfehlerrate aufweisen, in einem Zeitschlitz zu wiederholen, der die größte Entfernung zu der Übertragungslücke besitzt. 144

II. 145

Die Klagepatentansprüche lehren eine bestimmte Abbildung von Formatkennungsbits auf Formatkennungsstellen in einem im komprimierten Modus zu sendenden Rahmen. 146

1. 147

Ein Rahmen stellt nach dem Verständnis des Klagepatents eine zeitliche Struktur für zu übertragende Informationen – hier in Form von Bits – dar (Abs. [0003]; Textstellen ohne Bezugsangabe stammen aus der Patentschrift, Anlage KAP5). Zu den zu übertragenen Informationen gehören jedenfalls Formatkennungsbits (Merkmale 1 und 3), im UMTS-Standard auch TFCI-Bits genannt (Abs. [0003]). Daneben kann es noch weitere Systeminformationen wie die im Klagepatent genannten Pilotbits und TPC-Bits geben und die eigentlichen Daten (Abs. [0003]). Der Informationsgehalt des zu sendenden Rahmens ist jedenfalls nicht auf Formatkennungsbits beschränkt. 148

Der komprimierte Modus zeichnet sich nach den Klagepatentansprüchen dadurch aus, dass die innerhalb eines Rahmens zu sendenden Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb des komprimierten Rahmens eine Übertragungslücke vorhanden ist (Merkmal 2). Wie die zeitliche Komprimierung erzielt wird, lässt das Klagepatent offen. Dies kann dadurch geschehen, dass letztlich ein anderer Spreizfaktor verwendet wird, um denselben Informationsgehalt in der kürzeren zur Verfügung stehenden Zeit zu versenden. Ebenso ist es möglich, dass der Rahmen aufgrund der Übertragungslücke weniger Bits aufweist. Für die Lehre des Klagepatents ist jedenfalls entscheidend, dass infolge des komprimierten Modus für die Formatkennungsbits mehr Stellen zur Verfügung stehen können als Formatkennungsbits vorhanden sind (Merkmal 3). 149

Eine solche Situation kann eintreten, wenn der Rahmen in Zeitschlitze aufgeteilt ist, auf die im normalen Modus sämtliche zu sendenden Formatkennungsbits genau aufgeteilt sind. Fallen im komprimierten Modus einzelne Zeitschlitze weg, müssen die Formatkennungs-Stellen auf die verbleibenden Zeitschlitze mit einem geänderten Zeitschlitzformat neu verteilt werden (Abs. [0007]). Dies kann zur Folge haben, dass bei einem einheitlichen Zeitschlitzformat mehr Formatkennungs-Stellen als Formatkennungsbits zur Verfügung stehen (Abs. [0010]). Dies ist beispielhaft in den Figuren 4, 5A und 5B dargestellt. 150

151

2.

Wurde im Stand der Technik vorgeschlagen, insbesondere die unmittelbar nach der Übertragungslücke gesendeten Formatkennungsbits an freien Stellen zu wiederholen (Abs. [0011]; vgl. auch Merkmal 4), verlangt die Lehre der beiden Klagepatentansprüche darüber hinaus, die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abzubilden, um die nach dem ersten Abbilden noch freien Formatkennungs-Stellen des Rahmens mit einem Formatkennungsbit zu belegen (Merkmal 5). Sind beispielsweise nach dem ersten Abbilden noch drei Formatkennungs-Stellen des komprimierten Rahmens frei, werden diese mit den ersten drei unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits in umgekehrter Reihenfolge belegt. 152

Der Begriff „unmittelbar“ ist in diesem Zusammenhang dahingehend zu verstehen, dass die ersten Formatkennungsbits nach der Übertragungslücke wiederholt werden sollen. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass sich zwischen der Übertragungslücke und den ersten Formatkennungsbits andere Informationen befinden können. Der Wortlaut des Klagepatentanspruchs schließt eine solche Rahmenstruktur jedenfalls nicht aus. Vielmehr ergibt sich aus der Beschreibung des Klagepatents, dass eine Rahmenstruktur auch dann patentgemäß ist, wenn die ersten Bits, die der Übertragungslücke direkt nachfolgen, keine Formatkennungsbits sondern andere Informationsbits sind. 153

a) 154

Das Klagepatent geht von einem Stand der Technik aus, den der UMTS-Standard 3G TS 25.212 V3.0.0 repräsentiert (Abs. [0004]) und den die Klägerin als Anlage KAP 14 vorgelegt hat. Nach diesem UMTS-Standard folgen im komprimierten Modus auf eine Übertragungslücke sowohl im Uplink, als auch im Downlink immer Pilotsignale, bevor Formatkennungsbits in Form von TFCI-Bits gesendet werden (vgl. Ziff. 4.4.1 und 4.4.2 der Anlage KAP 14). Das technische Problem in Form einer unsicheren Sendeleistungsregelung unmittelbar nach der Übertragungslücke (Abs. [0011]) identifiziert das Klagepatent ausschließlich anhand dieses UMTS-Standards, auch wenn der Standard an dieser Stelle (Abs. [0011]) nicht mehr konkret genannt wird. Ein anderes Kommunikationssystem, in dem das genannte technische Problem besteht, wird in der Klagepatentschrift überhaupt nicht angesprochen. 155

Die patentgemäße Lösung besteht nun aber darin, die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden TFCI-Bits zu wiederholen und zwar in umgekehrter Reihenfolge (Merkmal 5; Abs. [0016]). Ausgehend von dem UMTS-Standard 3G TS 25.212 V3.0.0 handelt es sich daher bei „unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits“ im Sinne des Klagepatents um die ersten Formatkennungsbits, die nach einer Übertragungslücke gesendet werden, auch wenn sich zwischen diesen Bits und der Übertragungslücke noch andere Informationen befinden. Es kann hingegen nicht angenommen werden, dass die technische Lehre des Klagepatents auf eine Rahmenstruktur beschränkt sein soll, bei der die Formatkennungsbits zugleich die ersten Bits überhaupt sind, die auf die Übertragungslücke folgen. Denn dies führte dazu, dass gerade der Stand der Technik, an dem das Klagepatent das technische Problem festmacht, nämlich der UMTS-Standard 3G TS 25.212 V3.0.0, von der Lehre des Klagepatents nicht mehr erfasst ist. 156

b) 157

Die Lehre des Klagepatents zielt darauf ab, diejenigen Formatkennungsbits, die aufgrund ihrer Nähe zu der Übertragungslücke die größte Bitfehlerrate aufweisen, in einem Zeitschlitz 158

zu wiederholen, der die größte Entfernung zu der Übertragungslücke hat (Abs. [0016]). Handelt es sich bei den ersten Bits, die überhaupt auf eine Übertragungslücke folgen, nicht um Formatkennungsbits, wie dies im UMTS-Standard 3G TS 25.212 V3.0.0 bei den Pilotbits der Fall ist, haben innerhalb dieser Rahmenstruktur die ersten Formatkennungsbits, die auf diese anderen Bits nach der Übertragungslücke folgen, die größte Bitfehlerrate aller Formatkennungsbits.

Dem Klagepatent geht es darum, die Übertragungsleistung und die Übertragungssicherheit zu verbessern. Anknüpfungspunkt dafür sind die Formatkennungsbits, die dem Empfänger Informationen über das Format des Rahmens vermitteln. Ihre korrekte Übertragung soll sichergestellt werden. Anderen Systeminformationen wie der Pilotbitfolge oder den TPC-Bits, die in der Klagepatentschrift ebenfalls genannt werden (Abs. [0003]), scheint das Klagepatent hingegen keine oder jedenfalls eine geringere Bedeutung hinsichtlich der Übertragungssicherheit zuzumessen. Ebenso ist es möglich, dass der Übertragungssicherheit der anderen Systeminformationen auf andere Art und Weise Rechnung getragen wird. Dann ist es aber bei funktionaler Betrachtung fernliegend, die technische Lehre des Klagepatents auf Sachverhalte zu beschränken, bei denen das erste, der Übertragungslücke überhaupt folgende Bit ein Formatkennungsbit ist. Vielmehr ist es technisch sinnvoll, immer das erste Formatkennungsbit nach der Übertragungslücke zu wiederholen, selbst wenn andere Systeminformationsbits zwischen der Übertragungslücke und dem ersten Formatkennungsbit gesendet werden. 159

c) 160

Der Begriff „unmittelbar“ wird durch eine solche Auslegung nicht bedeutungslos. In Bezug auf die vorhandenen Formatkennungsbits wird klargestellt, dass das erste dieser Bits als letztes noch einmal gesendet werden soll, das zweite als vorletztes usw. Ohne den Begriff „unmittelbar“ wäre es gegebenenfalls auch möglich, nicht bereits das erste Formatkennungsbit zu wiederholen, sondern die wiederholte Übertragung mit anderen Formatkennungsbits zu bewerkstelligen. 161

d) 162

Schließlich ist auch der Umstand, dass der Begriff „unmittelbar“ erst im Erteilungsverfahren Eingang in die Klagepatentansprüche fand, nicht geeignet, eine abweichende Auslegung der Klagepatentansprüche zu begründen. Wie die Beklagten in der Klageerwiderung selbst feststellen, gab es hierfür aus dem Prüfungsverfahren heraus keinen Anlass. Darüber hinaus hat die Klägerin aber auch sonst keinen Grund für die Einfügung des Begriffs „unmittelbar“ genannt. Infolgedessen ist es alles andere als „offenbar“, dass es der Klägerin auf eine Einschränkung des Anspruchs ankam. Vielmehr gibt das Erteilungsverfahren für eine Auslegung in die eine oder andere Richtung schlicht nichts her. Selbst wenn man in der Einfügung des Begriffs „unmittelbar“ eine Einschränkung des Schutzgegenstands sehen wollte, kann diese auch in dem im vorherigen Absatz geschilderten Umfang bestehen. 163

III. 164

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht die Lehre des Klagepatentanspruchs 6 bzw. ist geeignet, das Verfahren gemäß Klagepatentanspruch 1 durchzuführen. 165

1. 166

167

Die angegriffene Ausführungsform verwendet ohne Ausnahme im Uplink bei Bedarf den im UMTS vorgesehenen Compressed Mode.

Die Beklagten weisen zu Recht darauf hin, dass der UMTS-Standard, soweit er das Senden von Daten im Compressed Mode betrifft, nicht zwingend ist. Denn die Frequenzmessungen, die in der im komprimierten Modus bereitgestellten Übertragungslücke durchgeführt werden sollen, können technisch auch mit einem zweiten RF-Receiver bewerkstelligt werden, ohne dass es eines Wechsels in den Compressed Mode bedarf. 168

Gleichwohl sind alle UMTS-fähigen Mobiltelefone der Beklagten, mithin die angegriffene Ausführungsform, geeignet, im Uplink in den vom UMTS-Standard vorgesehenen Compressed Mode zu wechseln und tun dies auch. Die Beklagten haben lediglich theoretisch eine Möglichkeit aufgezeigt, ohne den komprimierten Modus auszukommen. Dass die angegriffene Ausführungsform den Compressed Mode nach dem UMTS-Standard auch tatsächlich nicht anwendet, behaupten sie selbst nicht. Stattdessen hat die Klägerin für einzelne Exemplare der angegriffenen Ausführungsform durch Tests nachgewiesen, dass sie selbst dann in denCompressed Mode wechseln, wenn sie einen zweiten RF-Receiver aufweisen. Dem damit verbundenen impliziten Vortrag der Klägerin, die angegriffene Ausführungsform verwende ohne Ausnahme den im UMTS-Standard vorgesehenen Compressed Mode, sind die Beklagten nicht entgegengetreten. 169

2. 170

Die angegriffene Ausführungsform verwirklicht sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 6. Dies ist für die Merkmale 6.1 bis 6.3 unstreitig, gilt aber auch für die Merkmale 6.4 und 6.5. Insofern ist die angegriffene Ausführungsform auch geeignet, das mit dem Klagepatentanspruch 1 geschützte Verfahren nicht nur hinsichtlich der unstreitigen Merkmale 1.1 bis 1.3 durchzuführen, sondern auch hinsichtlich der streitigen Merkmale 1.4 und 1.5. 171

a) 172

Die angegriffene Ausführungsform ist geeignet, Rahmen in einem Komprimiermodus zu senden, wobei die innerhalb des zu sendenden Rahmens enthaltenen Informationen derart zeitlich komprimiert gesendet werden, dass innerhalb dieses komprimierten Rahmens eine nicht mit Informationen belegte Übertragungslücke vorhanden ist (Merkmal 1.2 bzw. 6.2). Der UMTS-Standard sieht mit dem Compressed Mode genau einen solchen Komprimiermodus vor. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig. 173

b) 174

Im UMTS-Compressed Mode werden die TFCI-Bits auf die für diese Bits zur Verfügung stehenden Stellen abgebildet. Dabei ist die innerhalb eines Rahmens zur Verfügung stehende Anzahl an Positionen für TFCI-Bits größer als die zu übertragende Anzahl von TFCI-Bits. Damit ist auch die Eignung der angegriffenen Ausführungsform für die Merkmale 1.3 bzw. 6.3 gegeben. 175

c) 176

Schließlich ist die angegriffene Ausführungsform im Compressed Mode geeignet, die die tatsächliche Anzahl an TFCI-Bits übersteigenden Positionen in dem zu sendenden Rahmen mit den unmittelbar der Übertragungslücke folgenden TFCI-Bits zu füllen, und zwar in 177

umgekehrter Reihenfolge. Es erfolgt also ein Mapping vonTFCI-Bits auf die entsprechenden Positionen, wobei die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden TFCI-Bits wiederholt abgebildet werden, in dem sie in umgekehrter Reihenfolge auf die noch verbleibenden Positionen für TFCI-Bits verteilt werden. Damit ist die angegriffene Ausführungsform geeignet, die TFCI-Bits entsprechend den Merkmalen 1.4 und 1.5 bzw. 6.4 und 6.5 auf die entsprechenden Positionen abzubilden.

Soweit die Beklagten eine Verwirklichung dieser Merkmale in Abrede stellen, beruht dies allein auf der Grundlage einer Auslegung, nach der sich die Lehre des Klagepatents allein auf einen Komprimiermodus beziehen soll, bei dem die Formatkennungsbits der Übertragungslücke ohne das Dazwischentreten anderer Bits unmittelbar nachfolgen sollen. Dass dem nicht gefolgt werden kann, wurde bereits ausgeführt. Nach zutreffender Auslegung werden die Merkmale 1.4 und 1.5 bzw. 6.4 und 6.5 daher auch im Hinblick auf den Begriff „unmittelbar“ verwirklicht. 178

IV. 179

Die Beklagten bieten die angegriffene Ausführungsform in der Bundesrepublik Deutschland an und bringen sie hier in den Verkehr. Dies ist zwischen den Parteien unstreitig und stellt eine Benutzung im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG dar. 180

Darüber hinaus verwirklichen Angebot und Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform auch die Voraussetzungen von § 10 Abs. 1 PatG. Bei den beanstandeten UMTS-fähigen Mobiltelefonen handelt es sich um Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen und von den Beklagten zur Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland angeboten und geliefert werden. Dabei ist den Beklagten bekannt, dass die Mobiltelefone dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Denn der Wechsel in den Compressed Mode ergibt sich zwangsläufig bei der Benutzung des Mobiltelefons unabhängig vom Willen des Nutzers. 181

V. 182

Die Wirkungen des Klagepatents treten jedoch für die Zeit bis zum XXXXXXXXX nicht ein, soweit UMTS-fähige Mobiltelefone der Beklagten angegriffen werden, die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sind. Für diesen Zeitraum und für diesen Teil der angegriffenen Ausführungsform können sich die Beklagten mit Erfolg auf den Grundsatz der Erschöpfung berufen. 183

1. 184

Erschöpfung meint Verbrauch des Patentrechts hinsichtlich eines bestimmten (einzelnen) patentgemäßen Erzeugnisses (BGH GRUR 1997, 116 – Prospekthalter). Wurde eine Sache, die die technische Lehre eines für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Vorrichtungspatents verwirklicht, vom Patentinhaber oder von einem von diesem ermächtigten Dritten in Deutschland, einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union (EU) oder einem dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehörigen Staat in den Verkehr gebracht, unterliegen das weitere Inverkehrbringen, Anbieten und Gebrauchen dieser Sache nicht mehr dem Verbietungsrecht aus dem Patent (BGH GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; GRUR 1997, 116, 117 – Prospekthalter; GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage). Gleiches gilt bei einem Verfahrenspatent für die nach § 9 S. 2 Nr. 3 PatG geschützten unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, soweit diese vom Patentinhaber oder mit dessen Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden (BGH GRUR 1980, 38, 39 – 185

Fullplastverfahren; GRUR 2001, 223, 224 – Bodenwaschanlage). Das wird im Grundsatz im gesamten Geltungsbereich des Europäischen Patentübereinkommens so gesehen (vgl. EuGH GRUR Int. 1995, 239, 241 – TRIPS-Kompetenz) und gilt gleichermaßen im gesamten gewerblichen Rechtsschutz (vgl. bspw. die Regelungen in § 24 MarkenG, § 17 Abs. 2 UrhG, § 10b SortSchG).

Im Einzelnen setzt die Erschöpfung des Patentrechts voraus, dass das erste Inverkehrbringen des patentierten Erzeugnisses oder des geschützten Verfahrenserzeugnisses in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Aufgrund des Grundsatzes des freien Warenverkehrs genügt es jedoch für den Eintritt der Erschöpfung, wenn der Patentinhaber oder der mit seiner Zustimmung handelnde Dritte die patentgeschützte Vorrichtung oder das geschützte Verfahrenserzeugnis in einem Mitgliedsstaat der EU in den Verkehr gebracht hat, selbst wenn in diesem Staat kein Patentschutz besteht (EuGH GRUR Int. 1974, 454 – Centrafarm; GRUR Int.1982, 47 – Merck; BGH GRUR 2000, 299 – Karate). Gleiches gilt regelmäßig für den Fall, dass die Sache außerhalb Deutschlands oder der EU in einem dem EWR angehörigen Staat in den Verkehr gebracht wurde (BGH GRUR 2000, 299 – Karate). Zulässig bleibt aber die Abwehr der Einfuhr patentgeschützter Erzeugnisse aus Mitgliedsstaaten der EU oder des EWR, in denen kein Patentschutz besteht, wenn die Erzeugnisse dort von Dritten ohne Zustimmung des Patentinhabers hergestelltoder in den Verkehr gebracht wurden. Ebenso kann sich der Patentinhaber grundsätzlich der Einfuhr solcher patentgemäßen Erzeugnisse widersetzen, die – sei es auch von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung – im Gebiet von Drittstaaten, die weder der EU noch dem EWR angehören, in den Verkehr gebracht wurden (BGH GRUR 2000, 299 – Karate; Kraßer/Ann, Patentrecht 7. Aufl.: § 33 V. d) 4. m.w.N.). Für das Inverkehrbringen gelten im Übrigen weitgehend vergleichbare Grundsätze wie für das Inverkehrbringen im Sinne von § 9 S. 2 Nr. 1 PatG (Schulte/Rinken, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn 26). 186

Die patentierte Vorrichtung beziehungsweise das unmittelbare Verfahrenserzeugnis muss zudem durch den Patentinhaber oder durch einen mit seiner Zustimmung handelnden Dritten in den Verkehr gebracht worden sein. Die Zustimmung kann ausdrücklich oder konkludent erteilt worden sein. Regelmäßig liegt die Zustimmung in der Erteilung einer Lizenz. Es genügt aber auch ein Verhalten, das den sicheren Schluss zulässt, dass der Patentinhaber mit dem Inverkehrbringen einverstanden ist (Benkard/Scharen, PatG 10. Aufl.: § 9 Rn 23; vgl. zum Markenrecht EuGH GRUR 2002, 156 – Davidoff; 2010, 723 – Coty Prestige; aA [nur ausdrückliche Zustimmung möglich] Kraßer/Ann, Patentrecht 7. Aufl.: § 33 V. b) 2.; Loewenheim GRUR 1982, 464). Die bloße Duldung patentverletzender Handlungen genügt regelmäßig nicht (Benkard/Scharen, PatG 11. Aufl.: § 9 Rn 23; Kraßer, Patentrecht 7. Aufl.: § 33 V. b) 2.). 187

2. 188

Nach diesen Grundsätzen sind die Rechte aus dem Klagepatent in Form von Anspruch 6 hinsichtlich der angegriffenen Modelle der Beklagten, die XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sind, für die Zeit XXXXXXX XXXXXXXX erschöpft. 189

a) 190

Die Beklagten bringen in der Bundesrepublik Deutschland Modelle der angegriffenen Ausführungsform in den Verkehr, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sämtliche Merkmale des Klagepatentanspruchs 6 191

verwirklichen. Es handelt sich dabei nach dem Vortrag der Beklagten unter anderem um folgende Geräte: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Diesem Vortrag ist die Klägerin nicht weiter entgegengetreten. Soweit sie darauf verweist, dass die von ihr untersuchten Modelle XXXXXXXXXXXXXXXXX, steht dies dem Vortrag der Beklagten nicht entgegen. Die Beklagten haben nie in Abrede gestellt, die angegriffene Ausführungsform XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX in Verkehr zu bringen. Vom Erschöpfungsgrundsatz betroffen sind allein die Modelle XXXXXXXXXXXXXX. 192

b) 193

Das Inverkehrbringen der Modelle XXXXXXXXXXXXX in der Bundesrepublik Deutschland bzw. den EWR durch die Beklagten erfolgte XXXXXXXXXXX mit der Zustimmung der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents. Zwar können sich die Beklagten selbst nicht unmittelbar auf eine von der Klägerin gewährte Lizenz berufen. Dessen bedarf es aber auch nicht, da XXXXXX eine Lizenz am Klagepatent hält und sich aus dem Lizenzvertrag zwischen der Klägerin und XXXXXX jedenfalls die konkludente Zustimmung der Klägerin für das erstmalige Inverkehrbringen von XXXXXXXXXXX im EWR – insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland – auch durch XXXXXXXXXXXXXXXXXX ergibt. 194

Mit Wirkung vom XXXXXXXX schlossen XXXXXX und die Klägerin eine Lizenzvereinbarung. Unter anderem räumte die Klägerin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Lizenz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX am Klagepatent ein (Anlage B11/B11a). Weiterhin ergibt sich aus XXXXXX der Lizenzvereinbarung, dass XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX anerkannt. Sie sollte nur für den Fall, dass XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

diesem Fall zur Erschöpfung, sondern die Zustimmung des Schutzrechtsinhabers zum grenzüberschreitenden Vertrieb.

Dass dieses Verständnis richtig ist und auch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 206
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, wird durch das weitere Verhalten der Klägerin nach Abschluss der Lizenzvereinbarung XXXXXXXXXXXXX belegt. Denn mit XXXXXXXXXxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Das gilt im Streitfall umso mehr, als der Verfahrensanspruch dieselben Merkmale wie der Vorrichtungsanspruch aufweist. Ist aber der Abnehmer XXXX

ebd., Kap. E., Rn. 229 a.E.). Ein solcher nachgeordneter Produktmarkt besteht für aufgrund des Patents lizenzpflichtige Waren/Dienstleistungen.

Nicht jedes standardessentielle Patent begründet als solches eine Marktbeherrschung (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 129; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 229). Eine solche ist jedoch ohne weiteres anzunehmen, wenn sich der Zugang zur Nutzung des fraglichen standardessentiellen Patents (im Folgenden auch kurz: SEP) als regelrechte Marktzutrittsvoraussetzung darstellt (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E, Rn. 232), was der Fall ist, wenn auf dem relevanten Markt überhaupt nur Produkte angeboten und nachgefragt werden, die den Standard durch Benutzung des SEP ausführen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, a.a.O.). Entsprechendes gilt, wenn auf dem relevanten Markt zwar auch Produkte angeboten werden, die die Produktkonfiguration des SEP nicht aufweisen, jedoch ein wettbewerbsfähiges Angebot ohne Zugang zur Nutzung des streitigen SEP nicht möglich ist (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 233). 222

Aus dem zuvor Gesagten folgt umgekehrt, dass mangelnde Standardessentialität eines Patents der Annahme einer Marktbeherrschung nicht zwangsläufig entgegensteht. Eine Marktbeherrschung kann sich auch ohne Standardessentialität aus einer technischen oder wirtschaftlichen Überlegenheit der patentierten Erfindung ergeben (OLG Düsseldorf, a.a.O.). 223

Der Beklagte trägt für die Marktbeherrschung nach den allgemeinen Grundsätzen die Darlegungs- und Beweislast (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 130; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 236). Er ist insoweit gehalten, ganz konkrete Tatsachen vorzutragen, die eine gerichtliche Überprüfung, ob eine beherrschende Stellung auf dem räumlich und sachlich relevanten Markt gegeben ist oder nicht, erlauben (Kühnen, a.a.O.). Für das Bestreiten des Patentinhabers gilt im Anschluss dasselbe Maß an Substantiierung (Kühnen, a.a.O.). 224

b) 225

Bei Berücksichtigung des unter lit. a) dargelegten Maßstabs haben die Beklagten eine marktbeherrschende Stellung der Klägerin auf dem hier relevanten Markt UMTS-fähiger Mobilfunkgeräte, der sich geographisch über das Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums erstreckt, dargetan. 226

Der von dem Klagepatent für den UMTS-Standard bereitgestellte Compressed Mode ist durch den Standard zwar nicht zwingend vorgegeben, vorgegeben ist danach lediglich, dass die Messungen, die der Compressed Mode ermöglicht (Inter-RAT und Inter-Freq.) in irgendeiner Form umgesetzt werden. Die in technischer Hinsicht bestehende Alternative zur Durchführung der in dem Standard vorgesehenen Messungen in Form der Implementierung eines zweiten Receivers, erfährt bisher auf dem Markt keine Umsetzung. Denn das Vorhandensein eines zweiten Receivers allein – wie er sich beispielsweise in Dual-Sim-Telefonen befindet – ist nicht ausreichend, es bedarf vielmehr einer technischen Herrichtung dieses Receivers zur Durchführung der Messungen. 227

Jedenfalls in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall folgt aus der Tatsache, dass die technisch mögliche Alternativlösung auf dem Markt bisher nicht verwirklicht ist, dass ein Produkt ohne Nutzung der klagepatentgemäßen Lehre nicht mit verhältnismäßigem Aufwand angeboten werden kann. 228

Zwar kann das Bestehen einer technischen Alternativlösung grundsätzlich auch dann gegen eine durch die geschützte Technik vermittelte marktbeherrschende Stellung sprechen, wenn diese Alternative erst noch auf dem Produktmarkt implementiert werden muss, mithin 229

Herstellungsprozesse und Vertriebsstrukturen erst auf diese angepasst werden müssen. Denn die Entscheidung, auf welche Art und Weise der Vertrieb des jeweiligen Produktes gestaltet werden soll – entweder durch die Schaffung organisatorischer und infrastruktureller Einrichtungen zur Umsetzung einer bestehenden technischen Alternative oder durch die Lizenznahme an der geschützten Technik – ist grundsätzlich Ausdruck eines vorhandenen unternehmerischen Ermessensspielraums, der gerade dagegen spricht, dass ein Zwang zum Rückgriff auf die geschützte Technik besteht. Etwas anderes gilt aber dann, wenn die Einführung der technischen Lösung entweder einen Kostenaufwand erfordert, durch den ein wettbewerbsfähiges Produkt nicht mehr angeboten werden kann – was vorliegend zwischen den Parteien streitig ist –, oder sich die Einführung aufgrund anderer Umstände als unverhältnismäßig aufwändig darstellt. Letzteres ist vorliegend der Fall.

Die Umsetzung der technischen Alternativlösung durch Herrichtung eines zweiten Receivers obliegt vorliegend nicht den Beklagten. Denn die Entscheidung über die Anwendung der klagepatentgemäßen Lehre erfolgt bereits bei den Herstellern der Chipsätze, die dann von dem Konzern der Beklagten in ihren Mobilfunkgeräten verbaut werden. Derzeit existieren auf dem Markt nur solche Chips, die zur Durchführung der Inter-RAT und Inter-Freq. Messungen die Lehre des Klagepatents zur Anwendung bringen. Der Rückgriff auf die technische Alternative eines zweiten Receivers würde für den jeweiligen Mobilfunkanbieter mithin bedeuten, dass er eine kundenspezifische Lösung auf Seiten des Chipherstellers anstrengen muss. Der Chiphersteller selbst sieht sich aufgrund der seit 2002 gelebten Herstellungspraxis und dem für diese vorhandenen Abnehmerkreis (Hersteller von Mobiltelefonen) zu einer grundsätzlichen Umstellung seiner Produktion auf die technischeAlternativlösung nicht veranlasst. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Umsetzung der technischen Alternative als unverhältnismäßig dar. 230

Nach alledem kommt es weder darauf an, ob die deutschen Netzbetreiber eine Zertifizierung der Mobilfunkgeräte verlangen, und diese ihrerseits die Umsetzung der klagepatentgemäßen Lehre fordert, noch kommt es auf den Marktanteil an, den diese Netzbetreiber innehaben. Die Klägerin bedurfte deshalb keiner Schriftsatzfrist zur Stellungnahme auf dieses Vorbringen der Beklagten. 231

2. 232

Die Klägerin nutzt ihre marktbeherrschende Stellung durch die auf Unterlassen, Rückruf und Vernichtung gerichtete Klage missbräuchlich im Sinne von Art. 102 AEUV aus. Denn ihr Verhalten diskriminiert die Beklagten sachwidrig. 233

a) 234

Der EuGH hat dem Inhaber eines standardessentiellen Patents, der sich gegenüber einer Standardisierungsorganisation dazu verpflichtet hat, jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen zu gewähren, in der Rechtssache Huawei Technologies/ ZTE, Az.: C-170/13 mit Urteil vom 16.07.2015 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 15.12.2015 (im Folgenden auch: das EuGH-Urteil oder die EuGH-Rechtsprechung) in Auslegung des Art. 102 AEUV Verpflichtungen auferlegt, die – sofern sie von diesem eingehalten werden – dazu führen, dass eine von diesem erhobene Klage auf Unterlassen oder Rückruf nicht als Missbrauch seiner marktbeherrschenden Stellung anzusehen ist (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 55), wobei die aufgestellten kartellrechtlichen Einschränkungen auch für den Vernichtungsanspruch gelten (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 16, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 345). 235

236

Aus dem in Bezug genommenen EuGH-Urteil ergibt sich ein von Patentinhaber und Patentbenutzer zu befolgendes Regime von Pflichten/ Obliegenheiten, dessen einzelnen Verfahrensschritte aufeinander aufbauen, so dass der Patentverletzer nur dann in der ihm obliegenden Art und Weise zu reagieren hat, wenn der Patentinhaber seinerseits zuvor die ihm oliegenden Pflichten erfüllt hat (OLG Düsseldorf, Beschl. vom 13.01.2016, Az.: I-15 U 65/15, Rn. 23, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 364, 377).

Dieses Regime sieht vor, dass der Patentinhaber den angeblichen Verletzter „vor Erhebung der Klage“ (bzw. „vor der gerichtlichen Geltendmachung“) unter Angabe des fraglichen SEP sowie der Art und Weise der Verletzung hinzuweisen hat (EuGH, GRUR 2015, 764, Rn. 62, 71). Hat der angebliche Patentverletzer daraufhin seine Lizenzbereitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrags unter FRAND-Bedingungen zum Ausdruck gebracht, hat der Patentinhaber – um sich nicht dem Vorwurf des Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung auszusetzen – ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen zu unterbreiten (EuGH, ebd., Rn. 71). Aus diesem müssen insbesondere die Lizenzgebühr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung hervorgehen (a.a.O.). Dem vermeintlichen Patentverletzer obliegt es sodann, auf dieses Angebot mit Sorgfalt, gemäß den in dem Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten und nach Treu und Glauben, zu reagieren (EuGH, ebd., Rn. 65, 71). Nimmt der vermeintliche Verletzer das Angebot nicht an, kann er sich auf die rechtsmissbräuchliche Geltendmachung einer Unterlassungs- oder Rückrufklage nur berufen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht (EUGH, ebd., Rn. 66). Weiter hat der Patentbenutzer ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt wurde, eine angemessene Sicherheit gemäß den in dem betreffenden Bereich anerkannten geschäftlichen Gepflogenheiten zu leisten (EuGH, ebd., Rn. 67). 237

b) 238

Auf die Verletzungsanzeige der Klägerin hat der Mutterkonzern der Beklagten seine grundsätzliche Lizenzbereitschaft erklärt (dazu unter lit. aa)). Anhaltspunkte dafür, dass diese mittlerweile entfallen ist, bestehen nicht (dazu unter lit. dd)). Während das Angebot der Klägerin aus August 2016 notwendige Erläuterungen zum Angebotsinhalt nicht erkennen lässt (dazu unter lit. bb)), kann das Angebot aus Februar 2018 inhaltlich nicht als FRAND-gemäß erachtet werden (dazu unter lit. cc)). 239

aa) 240

Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass die Muttergesellschaft auf die Verletzungsanzeige der Klägerin vom 03.08.2011 ihre grundsätzliche Lizenzbereitschaft erklärte, und sich dabei auch auf ihre Tochtergesellschaften, mithin auch die Beklagten, bezog. 241

Sofern die Klägerin meint, den Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft fehle es aber jedenfalls mittlerweile an der Bereitschaft zur Lizenznahme wird dazu unter lit. dd) weiter ausgeführt. 242

bb) 243

Das auf die Verletzungsanzeige folgende Schreiben der Klägerin an die Muttergesellschaft aus August 2016 (Anlage F8/1; deutsche Übersetzung: Anlage F8/1a) stellt kein FRAND-gemäßes Angebot im Sinne der unter lit. a) dargestellten EuGH-Rechtsprechung dar. Es fehlen schon notwendige Erläuterungen zu Lizenzverträgen mit Dritten. 244

(1) 245

Das FRAND-Vertragsangebot muss nach den von dem EuGH aufgestellten, eher „formellen“ Kriterien schriftlich verfasst und in dem Sinne konkret sein, dass daraus die Lizenzgebühr und die einschlägigen Berechnungsparameter (maßgebliche Bezugsgröße, anzuwendender Lizenzsatz, ggf. Abstaffelung) sowie die Art und Weise der Berechnung hervorgehen (OLG Düsseldorf, GRUR 2017,1219, Rn. 169 – Mobiles Kommunikationssystem; Kühnen, ebd., Kap. E. Rn. 354). Die Punkte, die üblicherweise Regelungsgegenstand von Lizenzverträgen sind, müssen in das Angebot in Form von aussagekräftigen Bestimmungen aufgenommen sein (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, a.a.O.). Das Angebot hat zu erläutern, aufgrund welcher Umstände die darin vorgeschlagenen Vergütungsparameter FRAND sind (OLG Düsseldorf, a.a.O.). 246

Mit der Angabe über die Art und Weise der Berechnung der Gebühren ist eine Erläuterung derjenigen Umstände gemeint, die die vertraglich nach Bezugsgröße und Lizenzsatz zu bezeichnenden Vergütungsfaktoren als diskriminierungs- und ausbeutungsfrei ausweisen (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 358). Dazu gehört auch, dass der Patentinhaber, soweit er bereits Lizenzen vergeben hat, nachvollziehbar macht, dass er den Lizenzsuchenden entweder gleich oder weshalb er ihn in welcher Hinsicht ungleich behandelt (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 22, zitiert nach juris; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166, Rn. 123 – Datenpaketverarbeitung; LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 311 ff., zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 360). 247

(2) 248

Die Anforderungen nach Ziffer (1) erfüllt der von der Klägerin im August 2016 vorgelegte XXXXXX auch unter Berücksichtigung der ihm beigefügten Anlagen jedenfalls insoweit nicht, wie die Darlegungen zur Art und Weise der Berechnung der vorgeschlagenen Lizenzgebühr betroffen sind. 249

Die Klägerin hat die der Muttergesellschaft im August 2016 angeboten Gebühren in ein Verhältnis mit den Lizenzgebühren gesetzt, die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vertraulichkeitsabreden enthalten sind, die jeglichen Verweis auf die Lizenzverträge – ggf. auch in anonymisierter Form – unmöglich machen ist nicht ersichtlich. Dagegen spricht auch, dass das – noch zu erörternde Angebot – aus Februar 2018 (dazu unter lit. cc)) jedenfalls rudimentäre Angaben zu den bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen enthält, indem XXXXXXXXXX XXXXXXXXX

Das Vertragsangebot der Klägerin enthält auch die nach dem EuGH-Urteil notwendigen Darlegungen zur Art und zum Umfang der Lizenzgebühren (vgl. zu den Anforderungen allgemein unter lit. bb), (1)). 261

Die Klägerin hat im Rahmen der XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX und diese erläutert. Soweit die Muttergesellschaft im Rahmen der XXXXXXXX Gespräche keine Informationen erhalten hat, mittels derer sie die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX im Hinblick auf die ihr angebotene XXXXXXXX ermessen konnte, hat die Klägerin diese Informationen im Rahmen des hiesigen Gerichtsverfahrens mit Schriftsatz vom 24.04.2020 (Bl. 436 ff. GA) nachgetragen (zur grundsätzlichen Nachholbarkeit: OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/16, Rn. 7, zitiert nach juris). Dabei kann hier noch dahinstehen, ob das Vorbringen der Klägerin die Diskriminierungsfreiheit im Ergebnis inhaltlich trägt (vgl. dazu unter Ziffer (2), (c), (b)). Jedenfalls legt die Klägerin zunächst ihre Lizenzierungspraxis dar, und ermöglicht den Beklagten damit, grundsätzlich eine Überprüfung des Angebots im Hinblick auf seine Diskriminierungsfreiheit. Eine solche Überprüfungsmöglichkeit bezweckt die nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. bb), (1) bestehende Erläuterungspflicht gerade. 262

Die Klägerin hat auch im Übrigen zur Angemessenheit der von ihr in Ansatz gebrachten XXXXXXXX der Höhe nach vorgetragen (vgl. zu diesem Erfordernis, Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 362). 263

Sie hat hierbei insbesondere in dem dem Schreiben vom 12.02.2018 beigefügten Memorandum näher zur Angemessenheit der Lizenzen ausgeführt und darin die angesetzten XXXXXXXX einerseits mit Lizenzen verglichen, die XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[…].“

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lässt sich weiter entnehmen: 272

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

beherrschten Markt gebildet hätte, erheblich überschreitet, es sei denn, es gibt eine wirtschaftliche Rechtfertigung für die Preisbildung (LG Düsseldorf, Teilurt. v. 31.03.2016, Az.: 4a O 73/14, Rn. 225, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 258). Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass eine mathematisch genaue Herleitung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr nicht zu erfolgen hat, vielmehr ist eine annäherungsweise Entscheidung, die auf Wertungen und Schätzungen beruht, vorzunehmen (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 484). Vergleichbare Lizenzverträge können dabei ein gewichtiges Indiz für die Angemessenheit der angebotenen Lizenzbedingungen sein (LG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 258 a. E.). Das Vertragsangebot hat sich des Weiteren auch im Hinblick auf die übrigen Vertragsbedingungen (lizenzpflichtige Schutzrechte, Lizenzgebiet usw.) als angemessen zu erweisen. Auch dabei kann eine beachtliche Zahl inhaltlich gleichlautender bereits abgeschlossener Verträge – sofern diese nicht unter Missbrauch von Marktmacht zustande gekommen sind – ein Indiz für die Angemessenheit der Vertragsbedingungen sein (LG Düsseldorf, Urt. v. 09.11.2018, Az.: 4a O 17/17, Rn. 389, zitiert nach juris).

Das Diskriminierungsverbot normiert für das marktbeherrschende Unternehmen eine Verpflichtung zur Gleichbehandlung, indem es Handelspartnern, die sich in gleicher Lage befinden, dieselben Preise und Geschäftsbedingungen einräumen muss (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 173 – Mobiles Kommunikationssystem). In das Gleichbehandlungsgebot sind dabei nur Sachverhalte, die auch vergleichbar sind, einzubeziehen, während auch marktbeherrschende Unternehmen auf unterschiedliche Marktbedingungen differenziert reagieren können (a.a.O.). Eine Ungleichbehandlung ist daher zulässig, wenn sie sachlich gerechtfertigt ist (a.a.O.). Der dem Inhaber eines gewerblichen Schutzrechts grundsätzlich zustehende weite Spielraum für eine sachliche Rechtfertigung ist eingeschränkt, wenn neben die marktbeherrschende Stellung weitere Umstände treten, aus denen sich ergibt, dass die Ungleichbehandlung die Freiheit des Wettbewerbs gefährdet (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 174). Diese können insbesondere darin bestehen, dass der Zugang zu einem nachgeordneten Produktmarkt von der Befolgung der patentgemäßen Lehre abhängig ist (BGH, GRUR 2004, 966 (968) – Standard-Spundfass) oder das Produkt – wie hier – erst bei Benutzung des Patents wettbewerbsfähig ist (OLG Düsseldorf, a.a.O.). 283

Die Darlegungs- und Beweislast für eine Ungleichbehandlung (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 177, Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 257, 335) liegt grundsätzlich bei dem Lizenzsucher. Jedoch ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass dieser regelmäßig keine nähere Kenntnis über die Lizenzierungspraxis des SEP-Inhabers, insbesondere über mit Dritten bestehende Lizenzverträge und deren Regelungsgehalt, besitzt. Dies rechtfertigt es, dem SEP-Inhaber, der naturgemäß in Kenntnis der Vertragsverhältnisse mit anderen Lizenznehmern ist und dem nähere Angaben hierzu auch zumutbar sind, insoweit eine sekundäre Darlegungslast aufzuerlegen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 335). Die Angabe zu den Lizenznehmern hat in diesem Zusammenhang vollständig zu erfolgen und darf nicht auf einige namenhafte Unternehmen der Branche reduziert werden (Kühnen, a.a.O.). Der Vortrag hat auch Angaben dazu zu enthalten, welche – konkret zu benennenden – Unternehmen mit welcher Bedeutung auf dem relevanten Markt zu welchen konkreten Konditionen eine Lizenz genommen haben (OLG Düsseldorf, a.a.O.). Regelmäßig ist die Vorlage der Lizenzverträge erforderlich (Kühnen, a.a.O.). Steht eine Ungleichbehandlung fest, so obliegt es dem Patentinhaber etwaige die unterschiedliche Behandlung rechtfertigende Umstände darzulegen und ggf. zu beweisen (OLG Düsseldorf, a.a.O.; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 335). 284

(b) 285

286

Das streitgegenständliche Vertragsangebot aus Februar 2018 (Anlage B4) diskriminiert die Beklagten.

Die Klägerin hat im Rahmen der sie treffenden sekundären Darlegungslast (dazu unter lit. (aa)) zwar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX und erläutert (dazu unter lit. (bb)), jedoch lässt dieses Vorbringen eine diskriminierungsfreie Vertragspraxis im Verhältnis zu den Beklagten nicht in hinreichendem Umfang erkennen (dazu insgesamt unter lit. (cc)). Denn eine Diskriminierung der Beklagten bleibt danach jedenfalls möglich oder ergibt sich teilweise sogar aus dem Klägervorbringen selbst. 287

Es ist auch davon auszugehen, dass die Diskriminierung der Beklagten dazu geeignet ist, den Wettbewerb zu beeinträchtigen (dazu unter lit. (dd)). 288

(aa) 289

Es verbleibt auch in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall bei der Verteilung der Darlegungslast wie unter lit. (a) beschrieben, obliegt es mithin der Klägerin, zu ihrer bisherigen Vertragspraxis vorzutragen, um den primär darlegungsbelasteten Beklagten ihrerseits Vorbringen zu einer etwaigen Diskriminierung zu ermöglichen. An dieser grundsätzlichen Verteilung der Darlegungslast ändert sich vorliegend nicht deshalb etwas, weil die Muttergesellschaft bei den außergerichtlichen Vertragsverhandlungen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hat (dazu unter lit. (aaa)). Auch ist die Vortragslast der Klägerin nicht deshalb reduziert, weil auf ihrer Seite bestehende Geheimhaltungsinteressen dies erfordern (dazu unter lit. (bbb)). 290

(aaa) 291

Vorliegend besteht eine sekundäre Darlegungslast der Klägerin, zu ihrer bisherigen Vertragspraxis vorzutragen, obwohl sie der Muttergesellschaft XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX hat. 292

(i) 293

Erhält die primär darlegungsbelastete Partei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Weitergabe der Informationen auch an ihre Tochtergesellschaften hindert. Denn auf Seiten der Tochtergesellschaften besteht dann das Informationsdefizit, das Anlass zu einer Verlagerung der Darlegungslast gibt, fort. Dieses Auseinanderfallen von Verhandlungs- und Prozessführung, das sich daraus ergibt, dass die Muttergesellschaft (mangels Zustellung der Klageschrift) nicht in das hiesige Verfahren einbezogen worden ist, mag aus Sicht der Klägerin unbefriedigend sein, der Konflikt lässt sich jedoch – wie das Gericht auch in seinem Beschluss vom 07.04.2020 (dort unter Ziff. 2., lit. a)) ausgeführt hat – aus den dargelegten Gründen mit den Mitteln des Prozessrechts nicht lösen. Insbesondere können die Beklagten nicht auf eine etwaige Erkundigungspflicht gegenüber ihrer Muttergesellschaft verwiesen werden. Denn dem steht im Falle eines mit der Muttergesellschaft bestehenden Geheimhaltungsabkommens entgegen, dass die Tochtergesellschaft bei vertragsgemäßem Verhalten des Mutterkonzerns – was zu unterstellen ist – auf Nachfrage keine Mitteilung von vertraulichen Informationen erhalten wird. Vorliegend bestehen auch keine Anhaltspunkte dafür, dass die Muttergesellschaft – entgegen der sie treffenden Geheimhaltungspflichten – Wissen über XXXXXXXXXX der Klägerin an die Beklagten weitergegeben hat. Soweit die Klägerin meint, ein Informationsaustausch zwischen den Beklagten und der Muttergesellschaft komme darin zum Ausdruck, dass die Beklagten im Rahmen des hiesigen Verfahrens vorgebracht haben, dass die Klägerin anderen Lizenznehmern wesentlich geringere Lizenzsätze gewähre, so lässt dieser pauschale Vortrag eine Kenntnis XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nicht erkennen. Er legt vielmehr nahe, dass – was die Beklagten auch vortragen – die Muttergesellschaft ihre Einschätzung der XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ausschließlich in eben dieser allgemeinen Form an die Beklagten weitergegeben hat.

Auch unter Anwendung der Grundsätze der Wissenszurechnung im Konzern sieht die Kammer die Beklagten nicht in der anfänglichen Darlegungslast für eine Diskriminierung, solange die näher bezeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft ihnen gegenüber Wirkung entfalten. In diesem Zusammenhang hat die Kammer bereits Zweifel daran, dass eine Wissenszurechnung allein aufgrund der Konzernzugehörigkeit der Beklagten bzw. allein aufgrund eines etwaigen Weisungsrechts nach § 380 AktG gerechtfertigt ist (kritisch auch Fleischer, in: Spindler/ Stilz, AktG, Kommentar, 4. Auflage, 2019, § 78, Rn. 56b). Jedenfalls verbietet sich eine Wissenszurechnung aber dort, wo – wie hier – Geheimhaltungsvereinbarungen die Weitergabe des bei der Muttergesellschaft vorhandenen Wissens hindern. Denn für eine Wissenszurechnung fehlt es dann an der rechtlich abgesicherten Zugriffsmöglichkeit (vgl. zu diesem Erfordernis: Fleischer, ebd., § 78, Rn. 56d) auf die jeweiligen Informationen – die bei einer Zurechnungsrichtung von bei der Muttergesellschaft nachgehaltenem Wissen an die Tochtergesellschaft ohnehin zweifelhaft ist. 296

Ausgehend von dem soeben Dargelegten konnten die Beklagten überhaupt erst dann in die Verantwortung zum Vortrag über die Lizenzierungspraxis der Klägerin genommen werden, als die Klägerin die Muttergesellschaft mit Vereinbarung vom 20.04.2020 (Anlage F20; F20/a), 297

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, 303

von ihrer Geheimhaltungspflicht gegenüber den Beklagten entbunden hat. Erst ab diesem Zeitpunkt ist zu erwägen, die Darlegungslast bei den Beklagten zu verorten. 304

(ii) 305

In dem hier zur Entscheidung stehenden Fall verbleibt es hingegen trotz der zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft am 20.04.2020 getroffenen Vereinbarung, mit der die Klägerin die Muttergesellschaft gegenüber den Beklagten von ihren aus der Geheimhaltungsvereinbarung vom 10.07.2018 erwachsenden Geheimhaltungspflichten befreite, bei einer sekundären Darlegungslast auf Seiten der Klägerin. 306

Denn die Befreiung der Klägerin von ihrer (sekundären) Darlegungslast entsprechend der unter Ziffer (i) dargelegten Grundsätze kann nur soweit reichen, wie ein Informationsdefizit des Lizenzsuchers durch Vertragsverhandlungen beseitigt worden ist. Im Hinblick auf solche Tatschen, die nicht Gegenstand der Verhandlungen waren, trifft die Klägerin hingegen weiterhin eine Obliegenheit vorzutragen. Vorliegend erhielt die Muttergesellschaft keine Erläuterungen zu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, die es ihr ermöglichten, XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX im Hinblick auf die ihr angebotenen Lizenzgebühren zu bewerten. Insbesondere im Hinblick auf XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zu erachten ist, sondern es vielmehr eine gewisse Bandbreite von Vertragsbedingungen gibt, die sich als FRAND-gemäß erweisen können (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 14, zitiert nach juris; OLG Karlsruhe, GRUR 2020, 166, Rn. 95 - Datenpaketverarbeitung). Innerhalb dieser Bandbreite ist ein anzuerkennendes Geheimhaltungsinteresse für den Lizenzgeber grundsätzlich denkbar (zu diesem Begründungsansatz: LG Mannheim, Urt. v. 04.09.2019, Az.: 7 O 115/15, S. 40, unveröffentlicht).

Eine rechtliche Relevanz kann das Vorbringen, vertragliche Vereinbarungen Dritter stünden der Offenlegung von Informationen entgegen, allerdings nur dann entfalten, wenn der Inhalt der angeblichen Vertraulichkeitsklausel im Einzelnen, das heißt mit dem genauen Wortlaut und unter Darlegung sämtlicher auslegungsrelevanter Umstände, bekannt ist (OLG Düsseldorf, a.a.O.; so wohl auch LG Mannheim, Urt. v. 04.09.2019, Az.: 7 O 115/15, S. 40, unveröffentlicht, wonach jedenfalls ein pauschaler Verweis nicht ausreichend sein dürfte). Hiervon ausgehend hat die Klägerin sodann darzulegen, weshalb ihr substantiierter Vortrag gerade wegen der Geheimhaltungsklausel und in welchem Umfang nicht möglich ist. 313

Die Klägerin hat ihre Geheimhaltungsinteressen nach dem gerichtlichen Hinweis vom 07.04.2020 (Bl. 391 ff. GA) hinreichend in diesem Sinne dargelegt. 314

Sie hat insbesondere unter Wiedergabe der mit ihren Lizenznehmern getroffenen Geheimhaltungsklauseln ausgeführt, dass danach sowohl die vereinbarten Lizenzbedingungen als auch die den jeweiligen Lizenznehmer betreffenden Informationen, die im Rahmen der Vertragsverhandlungen ausgetauscht worden sind, geheim zu halten sind. Dieser Inhalt lässt sich anhand der vorgelegten Klauselnauch nachvollziehen. So heißt es in Artikel 8 des einen als Anlage F18 (deutsche Übersetzung: Anlage F18/a) auszugsweise vorgelegten Vertragsdokuments: 315

XXXX

Nachdem die Beklagten und die Muttergesellschaft Geheimhaltungsabkommen mit der Klägerin abgeschlossen haben, und das Gericht eine Vorlageanordnung erlassen hat, sind die Geheimhaltungsinteressen der Klägerin hinreichend gewahrt, so dass ihr vollumfänglicher Vortrag zu ihrer bisherigen Lizenzierungspraxis möglich ist. 322

Sofern ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse des SEP-Inhabers dargetan ist, kann dies im Rahmen eines Verletzungsprozesses, der den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand zum Gegenstand hat, grundsätzlich in der Weise Berücksichtigung finden, dass demjenigen, demgegenüber ein Geschäftsgeheimnis im gerichtlichen Verfahren offenzulegen ist, abverlangt wird, sich im Rahmen einer strafbewehrten Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verschwiegenheit zu verpflichten (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 6087, Rn. 127 – Improving Handovers; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 14.12.2016, Az.: I-2 U 31/16, Rn. 5, zitiert nach BeckRS 2016, 114380; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 17.11.2016, Az.: I-15 U 66/15, Rn. 25, zitiert nach juris; LG Düsseldrof, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 154/15, Rn. 320, zitiert nach juris; Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 512). Weigert sich der Prozessgegner eine zum Geheimnisschutz notwendige und zumutbare Sicherungsvereinbarung zu treffen, so ist der Darlegungsmaßstab des SEP-Inhabers zur Rechtfertigung seines Lizenzangebots auf pauschale, andeutende Angaben beschränkt, die seine Geschäftsgeheimnisse schützen; sie sind dann als prozessual ausreichend zu erachten und ein hierauf bezogenes Bestreiten des Gegners als unbeachtlich zu werten (a.a.O.). 323

Verschwiegenheitsverpflichtungen in diesem Sinne sind zwischen den Beklagten und der Klägerin am 20.04.2020 (Anlage F19) geschlossen worden, darüber hinaus enthält auch die das Geheimhaltungsabkommen mit der Muttergesellschaft vom 10.07.2018 ergänzende Vereinbarung zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft vom 20.04.2020 (Anlage F20; deutsche Übersetzung: Anlage F20a) Regelungen, die die Geheimhaltungsinteressen der Klägerin weiter schützen. Sofern danach nämlich eine Berechtigung der Muttergesellschaft zur Kenntnisnahme der von der Klägerin in den hiesigen Prozess mit den Beklagten eingeführten Informationen besteht, 324

XXXX

der SEP-Inhaber seinen Sachvortrag ohne eigenes Verschulden nicht substantiieren könne, weil er die Geheimhaltungsanordnung gerade nicht veranlasst habe oder diese ohne seine Mitwirkung zustande gekommen sei (Kühnen, ebd., Rn. 507 f.). Jedoch wird auch in den Fällen, in denen der SEP-Inhaber auf die Geheimhaltungsanordnung des ausländischen Gerichts hingewirkt hat, grundsätzlich für möglich erachtet, eine Vorlageanordnung nach § 142 ZPO zu treffen (Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 509). Ausschlaggebend sei hierbei, dass die Vorlageanordnung weder den Gegner noch das Gericht belaste, während sie dem Kläger eine weitergehende Teilhabe an dem Prozess ermögliche (a.a.O.).

Mit diesen Konstellationen hält die Kammer den hier vorliegenden Fall insoweit für vergleichbar, als die zwischen den Parteien getroffenen Geheimhaltungsvereinbarungen allein nicht ausreichend sind, um die Geheimhaltungsinteressen zu waren. Vielmehr bedarf es nach dem konkreten Wortlaut der mit den anderen Lizenznehmern getroffenen Geheimhaltungsklauseln einer gerichtlichen Vorlageanordnung, 331

XXXX

Weiter begegnet es für die Ermittlung der Referenzlizenzverträge als solchen keinen Bedenken, dass sich die Klägerin unter Bezugnahme auf die oberlandesgerichtliche Rechtsprechung (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 6087, Rn. 123 – Improving Handovers) lediglich auf solche Lizenzverträge bezieht, die im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung noch laufend sind. Die Begründung für eine solche Beschränkung der Vorlagepflicht liegt nach der zitierten Rechtsprechung darin, dass sich aus den bereits beendeten Lizenzverträgen keine Auswirkungen mehr auf die Wettbewerbslage der Konkurrenten ergeben können (OLG Düsseldorf, a.a.O.).

Sofern – auch nach der zitierten Rechtsprechung – bereits abgelaufene Verträge gleichwohl eine Relevanz entfalten können, nämlich für die Beurteilung, ob Referenzlizenzverträge ihrerseits ausbeutungs- und diskriminierungsfrei zustande gekommen sind (vgl. Kühnen, ebd., Kap. E., Rn. 494), wird zur Erheblichkeit solcher Verträge insoweit für den hier zur Entscheidung stehenden Fall unter lit. (cc), (bbb), (iii) weiter ausgeführt. Soweit die Klägerin als weiteres Auswahlkriterium solche Lizenzverträge aus der Vergleichsmenge herausnimmt, die XXXXXXXXXXXXXX enthalten, wird dazu unter lit. (cc), (ddd) weiter ausgeführt. 344

(bbb) 345

Die Klägerin legt auf der Grundlage der unter lit. (aaa) dargestellten Auswahlkriterien im Ergebnis die Verträge mit ihren Lizenznehmern XXXXXXXXXX als für den Vergleich mit dem streitgegenständlichen Vertragsangebot relevante Verträge vor. Die darin vorgesehenen XXXXXXXXXXXXX

Zu dem Wert XXXXXXXX als der den Beklagten angebotenen Lizenzgebühr gelangt die Klägerin dabei, indem sie die in der Tabelle nach Anlage 1 ihres Vertragsentwurfs (Anlage B4) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (vgl. Triplik Teil II., v. 17.02.2020, S. 48, Rn. 158, Bl. 369 GA). Gegen ein solches Vorgehen spricht aus Sicht der Kammer nichts. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Die Beklagten treten auch weder diesem Vorgehen noch der Höhe der von der Klägerin ermittelten XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX entgegen.

(cc) 361

Das so ausgestaltete Vorbringen der Klägerin zur Diskriminierungsfreiheit ihres Vertragsangebots im Verhältnis zu ihrer bisherigen Vertragspraxis erweist sich jedoch aufgrund von vier Gesichtspunkten als unzureichend. 362

Erstens bleibt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, weshalb eine Diskriminierung im Verhältnis zu den Beklagten nicht ausgeschlossen werden kann (dazu unter lit. (aaa)). Zweitens stellt sich die XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX als zweifelhaft dar. Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, dass die für einen Vergleich maßgebliche Lizenzspanne tatsächlich niedriger (und damit ggf. insgesamt unterhalb der der Klägerin angebotenen Lizenzgebühren) anzusetzen ist (dazu unter lit. (bbb)). Drittens hat die Klägerin nicht nachvollziehbar dargetan, dass es keine weiteren, für den Vergleich wesentlichen Lizenzverträge mit anderen Lizenznehmern gibt (dazu unter lit. (ccc)). Viertens gibt der eigene Vortrag der Klägerin Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagten durch das Vertragsangebot ohne sachlichen Grund insoweit ungleich behandelt werden, als XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (dazu unter lit. (ddd)). 363

(aaa) 364

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bleibt unklar, so dass bereits auf der Grundlage des Klägervortrags nicht ausgeschlossen werden kann, dass Ausgangspunkt der Verhandlungen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ZPO – ungeeignet, die Klägerin von ihrer Vortragslast zu entbinden.

Gem. § 138 Abs. 1 ZPO hat sich die (ggf. sekundär) darlegungsbelastete Partei zu Tatsachen vollständig und der Wahrheit gemäß zu erklären. Nach der Wertung des § 138 Abs. 4 ZPO kann eine Erklärung mit Nichtwissen nur im Hinblick auf solche Tatsachen erfolgen, die außerhalb der eigenen Wahrnehmung der Partei liegen, was auf die Vertragsverhandlungen der Klägerin XXXXXXXXXX nicht zutrifft. Hat die Partei zu einer Tatsache kein aktuelles Wissen, treffen sie – soweit zumutbar und möglich – Informationspflichten, wobei insbesondere im eigenen Unternehmensbereich Erkundigungen auch bei früheren Mitarbeitern einzuholen sind (BGH, GRUR 2002, 190 (191)). Das gilt vorliegend umso mehr als die Vertragsverhandlungen XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 369

Dass die Klägerin versucht hat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ist nicht dargetan. 370

(ii) 371

Damit aber bleibt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 372
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

(i) 393

Sortiert der Lizenzgeber Vertragsverhältnisse aus der Menge der Vergleichsverträge aus, so ist das Kriterium, mit welchem er die Nichtvorlage begründet, sorgfältig daraufhin zu überprüfen, ob damit tatsächlich einem Vergleich nicht zugängliche Verträge aus der Referenzmenge herausgenommen werden, oder ob damit der Vergleichsmaßstab unsachgerecht eingeengt wird und sich der Lizenzgeber auf diese Weise einer grundsätzlich notwendigen Rechtfertigung für eine Ungleichbehandlung entzieht. Von der grundsätzlich bestehenden Vorlagepflicht können deshalb nur solche Verträge ausgenommen werden, bei denen die Unterschiede derart groß sind, dass sich von vornherein keine Argumente für eine Gleichbehandlung finden lassen. Das trifft auf solche Lizenzverhältnisse zu, deren Inhalt unter keinem Gesichtspunkt mit demjenigen des Vertragsangebots so auf einen Nenner gebracht werden kann, dass ein Vergleich möglich wird. 394

Ausgehend von diesen Erwägungen eignen sich Lizenzverträge XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX grundsätzlich nicht für einen Vergleich gegenüber solchen Lizenzsuchern, die XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Denn bei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Schließlich ergibt sich aus dem Vorbringen der Klägerin selbst eine sachwidrige Benachteiligung der Beklagten insoweit, als die Klägerin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ansatz gebracht worden ist, reicht dies für eine Eignung zur Wettbewerbsbeeinträchtigung grundsätzlich aus. Denn jede Lizenzgebühr, die für ein standardessentielles Schutzrecht aufgebracht werden muss, repräsentiert einen Kostenfaktor, der in die Preisbildung auf dem nachgelagerten Produktmarkt eingeht und damit potenziell geeignet sein kann, die Position des Anbieters im Wettbewerb zu beeinträchtigen (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 6087, Rn. 124 – Improving Handovers). Eines darüber hinaus gehenden zusätzlichen Beweises einer tatsächlichen und quantifizierbaren Verschlechterung der Wettbewerbsstellung einzelner Handelspartner bedarf es daneben nicht (EuGH, NZKart 2018, 225, Rn. 27).

dd) 424

Die nach Maßgabe der Ausführungen unter lit. cc) anzunehmende sachwidrige Ungleichbehandlung ist auch nicht deshalb unerheblich, weil aufgrund des Gesamtverhaltens der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft davon auszugehen ist, dass diese – entgegen ihrer anfänglich erklärten Lizenzbereitschaft – zu einer Lizenznahme nunmehr nicht (mehr) bereit sind, sie mithin auf ihrer Seite schon die vom EuGH aufgestellten Anforderungen an das „FRAND-Procedere“ nicht erfüllen. 425

Der Einwand der Klägerin, dass es an der erforderlichen Lizenzbereitschaft der Beklagten mittlerweile fehle, ist insoweit beachtlich, als es nicht ausreichend sein kann, die Lizenzbereitschaft zu Beginn der Vertragsverhandlungen einmalig zu erklären, wenn das tatsächliche Verhalten des Lizenzsuchers in den sich dann anschließenden Vertragsverhandlungen der erklärten Lizenzbereitschaft entgegensteht. Denn die Bereitschaft zur Lizenznahme muss die Vertragsverhandlungen stetig begleiten (OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 161 – Mobiles Kommunikationssystem; Kühnen, ebd., Kap. H., Rn. 371), und darin einen Ausdruck finden, dass der Lizenzsucher, auch wenn er nach den Anforderungen des EuGHs zunächst nicht in der Schuld für ein FRAND-gemäßes Angebot ist, an dem Zustandekommen eines Lizenzvertrags konstruktiv mitwirkt (Kühnen, ebd., Kap. H., Rn. 384). 426

In dem hier vorliegenden Fall kann jedoch nicht festgestellt werden, dass es an der Bereitschaft der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft zur Lizenznahme in diesem Sinne fehlt. Weder das Fehlen eines Gegenangebots (dazu unter Ziff. (1)) noch ein zögerliches Verhalten im Übrigen (dazu unter Ziff. (2)) rechtfertigen eine solche Annahme. 427

(1) 428

Der Muttergesellschaft kann nicht vorgeworfen werden, dass diese ihrerseits weder auf das Schreiben aus August 2016 noch auf dasjenige aus Februar 2018 mit einem Gegenangebot reagiert hat. 429

Denn unbeschadet der Frage, ob eine Pflicht für ein Gegenangebot nach dem Verhandlungsregime des EuGH erst dann besteht, wenn der Lizenzgeber seinerseits ein Angebot, welches inhaltlich FRAND-Kriterien entspricht, unterbreitet hat (so die bisheriger OLG-Rechtsprechung: OLG Düsseldorf, GRUR 2017, 1219, Rn. 166 – Mobiles Kommunikationssystem; OLG Karlsruhe, GRUR-RS 2016, 17467, Rn. 33 ff. - Dekodiervorrichtung), haben die Beklagten Kenntnis von Tatsachen, die für die Beurteilung der Diskriminierungsfreiheit des an sie gerichteten Vertragsangebots maßgeblich sind, entweder – wie im Falle des Schreibens aus August 2016 – gar nicht (vgl. dazu unter lit. bb), (2)), oder aber – wie im Zusammenhang mit dem Angebot aus Februar 2018 – erst im Rahmen des hiesigen Gerichtsverfahrens mit Schriftsatz der Klägerin vom 24.04.2020 erlangt (vgl. dazu unter lit. (cc), (1), (b)). Der Lizenzsucher kann aber jedenfalls solange nicht zur Abgabe eines Gegenangebots verpflichtet sein, wie ihm für die Bewertung des Angebots des 430

Lizenzgebers unter FRAND-Gesichtspunkten maßgebliche Informationen fehlen.

Aber auch nachdem die Klägerin nunmehr weiter zu ihrer Lizenzierungspraxis vorgetragen hat, können die Beklagten bzw. die Muttergesellschaft, der nach der ergänzenden Vertraulichkeitsvereinbarung vom 20.04.2020 mit der Klägerin in Kenntnis über ihren Prozessvortrag zur Lizenzierungspraxis gesetzt werden kann (vgl. dazu unter cc), (2), (b), (aa), (bbb), (ii)), nicht darauf verwiesen werden, der Klägerin ein Gegenangebot unterbreiten zu müssen. Denn auch dieses Vorbringen lässt nicht erkennen, welche Lizenzgebühr sich in die bisherige Lizenzierungspraxis diskriminierungsfrei einfügt. Vielmehr bestehen auch auf Grundlage des ergänzenden Klägervorbringens die unter lit. cc), (2), (b), (cc) aufgezeigten Unklarheiten. Würde man es auch in einem Fall wie dem vorliegenden den Beklagten auferlegen, ein Lizenzangebot an die Klägerin zu richten, bestünde das Risiko, dass sich die Beklagten damit an Lizenzgebühren binden, die tatsächlich nicht diskriminierungsfrei sind. Soweit die Klägerin in diesem Zusammenhang weiterbemängelt, dass sich die Beklagten nicht zu dem tatsächlichen Wert ihres, der Klägerin, Portfolios verhalten, ergibt sich auch daraus keine andere Bewertung. Der wirtschaftliche Wert des Portfolios betrifft in erster Linie die Frage der Angemessenheit des Lizenzvertragsangebots, während er für die Beurteilung der Diskriminierungsfreiheit lediglich mittelbar eine Relevanz entfaltet. Denn die bisherige Vertragspraxis des Lizenzgebers, an welcher das Vertragsangebot an den Lizenzsucher unter Diskriminierungsgesichtspunkten zu messen ist, muss sich nicht zwingend an dem wirtschaftlichen Wert eines Portfolios orientieren. Vielmehr ist denkbar, dass der Lizenzgeber Lizenzen unterhalb des wirtschaftlichen Werts seines Portfolios vergeben hat, weil er Interessen der bisherigen Lizenznehmer im Rahmen der Vertragsverhandlungen in größerem Umfang Rechnung tragen musste. Dann aber müssen auch die Beklagten, jedenfalls ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes, keine an dem wirtschaftlichen Wert ausgerichteten Lizenzgebühren nehmen. Vielmehr sind die Lizenzgebühren auch für die Beklagten – im Sinne einer Gleichbehandlung mit den übrigen Lizenznehmern – an den Vergleichslizenzen auszurichten. 431

Unter Berücksichtigung des soeben Ausgeführten übt die Kammer das ihr nach Art. 267 AEUV im Hinblick auf die Herbeiführung einer Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union eingeräumte Ermessen dahingehend aus, dass es einer solchen vorliegend – entgegen der Anregung der Klägerin – nicht bedarf. 432

(2) 433

Auch im Übrigen lässt sich dem Verhalten der Beklagten nicht entnehmen, dass sie die Vertragsverhandlungen bewusst verzögern und eine Lizenznahme tatsächlich nicht mehr anstreben. 434

(a) 435

Die Kammer verkennt nicht, dass auf der Grundlage des Parteivorbringens nach der Verletzungsanzeige im August 2011 über einen Zeitraum von fünf Jahren keine Vertragsverhandlungen stattgefunden haben, bevor dann die Klägerin im August 2016 ein Vertragsangebot unterbreitet hat. Die Gründe für eine derart lange Verhandlungspause sind dem Parteivorbringen jedoch nicht zu entnehmen, weshalb diese auch nicht in dem Verantwortungsbereich der Beklagten verortet werden kann. Dies gilt umso mehr, als sich nach der Rechtsprechung des EuGH an dieLizenzierungsbereitschaftserklärung des Lizenzsuchers eine Aktivität des Lizenzgebers, nämlich ein auf den Abschluss eines FRAND-gemäßen Vertrags gerichtetes Angebot, ausschließen muss (LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Az.: 4a O 16/16, Rn. 305 ff. – Kommunikationsvorrichtung, zitiert nach juris). 436

Dagegen, dass die Klägerin von einem solchen aufgrund eines Verhaltens der Beklagten bzw. des Mutterkonzerns absah, das nahelegte, dass dieser nicht mehr lizenzwillig ist, spricht schon, dass dem Mutterkonzern schließlich im August 2016 ein Schreiben mit der Absicht zum Abschluss eines Vertragsschlusses angetragen wurde.

(b) 437

Die Muttergesellschaft hat sodann sowohl auf das Schreiben aus August 2016 als auch auf dasjenige aus Februar 2018 jeweils innerhalb vertretbarer Zeiträume reagiert, und hierbei eine von einem um einen Vertragsschluss ernsthaft bemühten Lizenznehmer zu erwartende inhaltliche Auseinandersetzung erkennen lassen. 438

Rund zwei Monate nachdem die Klägerin im August 2016 ihr Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags unterbreitet hatte, meldete sich die Muttergesellschaft mit E-Mail vom 17.10.2016 und mahnte darin unter anderem die fehlenden Ausführungen zur bisherigen Lizenzierungspraxis an (vgl. die insoweit im Ergebnis übereinstimmenden gerichtlichen Ausführungen hierzu unter lit. bb), (2)), 439

„XXXX

Insoweit kann auch der Klägervortrag, wonach die Beklagten ihre Kritik XXXXXXXX XXXXXXXXXXX vorgerichtlich nicht thematisiert hätten, nicht nachvollzogen werden.

Darauf, ob die Einwände im Ergebnis allesamt durchgreifen, kann es für die Frage der Lizenzbereitschaft nicht ankommen. Jedenfalls solange, wie die Einwände nicht ganz offensichtlich haltlos sind, muss es dem Lizenzsucher im Rahmen seiner Rechtsverteidigung möglich sein, Kritik an einzelnen Klauseln zu üben. Das gilt insbesondere dann, wenn er diese – wie vorliegend – auch schon vorprozessual vorgebracht hat. Allein die Tatsache, dass die Muttergesellschaft in diesem Zusammenhang keine konkreten Vorschläge für eine Umformulierung der von ihr im Hinblick auf die FRAND-Konformität als bedenklich eingestuften Klauseln unterbreitet hat, vermag die Kammer – jedenfalls in dem hier zur Entscheidung stehenden Fall – nicht als Ausdruck einer fehlenden Lizenzbereitschaft zu werten. Dagegen steht zum einen das im Übrigen – wie beschrieben – konstruktive Verhalten der Beklagten. Zum anderen erscheint es der Kammer aber auch nicht branchenüblich, dass Verhandlungen über einzelne Klauseln eines Angebots stets über die schriftliche Fixierung alternativer Klauseln geführt werden. 449

Auf das Schreiben der Muttergesellschaft vom 14.08.2018 folgte bereits am 21.09.2018 die Klageerhebung. Dennoch kam es am 13.12.2018 zum Abschluss einer weiteren Vertraulichkeitsvereinbarung zwischen der Klägerin und der Muttergesellschaft der Beklagten, mit dem Ziel die Vertragsverhandlungen fortzusetzen, was den Fortbestand der grundsätzlichen Verhandlungsbereitschaft der Muttergesellschaft suggeriert. Dass die Beklagten dann in der Folge der prozessualen Auseinandersetzung keine konkreten Angaben dazu machten, welche Lizenzgebühr sich ihrer Meinung nach als diskriminierungsfrei darstellen würde, kann ihnen unter dem Aspekt der fehlenden Lizenzierungsbereitschaft nicht vorgeworfen werden. Insoweit gilt das zum Fehlen eines Gegenangebots unter Ziff. (1) Dargelegte entsprechend. Auch kann das Verhalten der Beklagten, wonach diese im Rahmen des hiesigen Prozesses Erläuterungen zur Vertragspraxis der Klägerin verlangten, nicht als Verzögerungstaktik gewertet werden. Soweit die Klägerin meint, diese Forderung stelle sich vor dem Hintergrund als bloße Förmelei dar, dass die notwendigen Erläuterungen bereits der Muttergesellschaft gegeben worden seien, so kann dem nicht gefolgt werden. Es wird auf die Ausführungen zur Beurteilung der Darlegungslast, die hier entsprechend gelten, verwiesen (vgl. unter lit. cc), (2), (b), (aa), (aaa), (ii)). Zwischen der Muttergesellschaft und den Beklagten bestand danach durch die Geheimhaltungsvereinbarungen mit der Klägerin eine Informationsbarriere, aufgrund derer die Beklagten (die zur Rechtsverteidigung notwendigen) Kenntnisse zur Lizenzierungspraxis der Klägerin gerade nicht hatten. 450

(c) 451

Schließlich vermag die Kammer auch aus der Tatsache, dass der Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens zu prozessualen Zwecken sowohl mit den Beklagten als auch mit der Muttergesellschaft zunächst scheiterte, nicht zu schließen, dass auf Beklagtenseite eine Lizenzbereitschaft nicht besteht. 452

In die in diesem Zusammenhang vorzunehmende Gesamtbetrachtung des Verhaltens der Beklagten bzw. ihrer Muttergesellschaft ist zunächst einzustellen, dass diese sich – wie unter lit. (b) aufgezeigt – im Rahmen der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Vertragsangebot konstruktiv gezeigt haben. Sofern sie sich dann dem von der Klägerin vorgelegten Entwurf für den Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens zu prozessualen Zwecken vom 03.06.2019 (Anlage F1) zunächst verschlossen haben, ergibt sich daraus allein eine Lizenzunwilligkeit nicht (zu dieser grundsätzlichen Betrachtungsweise: LG Düsseldorf, Urt. v. 13.07.2017, Rn. 370 ff. – Kommunikationsvorrichtung, zitiert nach juris, wonach aus 453

einer unberechtigten Verweigerung zum Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens für den Lizenzsucher stets „nur“ die hier bereits beschriebenen nachteiligen prozessualen Folgen erwachsen.)

Dem Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens zu prozessualen Zwecken stand zunächst in erster Linie entgegen, dass die Klägerin die Aufnahme der Muttergesellschaft in eine entsprechende Vereinbarung anstrebte, weil sie – grundsätzlich nachvollziehbar – befürchtete, dass Schriftsätze mit geheimhaltungsbedürftigem Inhalt gegenüber den Beklagten, wenn diese sich zur Geheimhaltung verpflichten würden, offenbart würden, und diese auch gegenüber der Muttergesellschaft nach deren Eintritt in das Verfahren (mithin nach bewirkter Zustellung der Klageschrift) zur Kenntnis gebracht würden, ohne dass diese sich ihrerseits zur Geheimhaltung verpflichtet hat. Bezogen auf die Beklagten hingegen ist anzuerkennen, dass rechtliche und tatsächliche Einwirkungsmöglichkeiten auf die Muttergesellschaft, um diese zur Unterschriftsleistung zu bewegen, nicht erkennbar sind, weshalb zunächst ebenso nachvollziehbar ist, dass sie der vorgeschlagenen Geheimhaltungsvereinbarung vom 03.06.2019 (Anlage F1), die gerade auch die Muttergesellschaft als Vertragspartei vorsieht, nicht beigetreten sind. 454

Als Anknüpfungspunkt für die Annahme einer fehlenden Lizenzbereitschaft kann daher überhaupt nur ein zögerliches Verhalten der Muttergesellschaft in Betrachtkommen, die in Kenntnis des hiesigen Prozesses und insbesondere in Kenntnis des Entwurfs der Klägerin vom 03.06.2019 erklärte, eine Geheimhaltungsvereinbarung erst nach Eintritt in das Verfahren unterzeichnen zu wollen. Damit hat die Muttergesellschaft eine nach Einschätzung der Kammer unzutreffende Rechtsauffassung kundgetan, dies aber kann nicht als Ausdruck von Lizenzunwilligkeit gewertet werden. Denn auch, wenn die formal fehlende Stellung der Muttergesellschaft als Prozesspartei keinen hinreichenden Weigerungsgrund für die Unterzeichnung eines Geheimhaltungsabkommens zu prozessualen Zwecken bietet, sind im Zusammenhang mit einem solchen doch die schützenswerten Interessen der Muttergesellschaft zu berücksichtigen. Diese bestehen zum einen darin, dass sie ihrerseits Kenntnis von im Rahmen des Prozesses ausgetauschten Informationen erhalten kann – was ihr nicht möglich ist, wenn die Beklagten an ein Geheimhaltungsabkommen mit der Klägerin gebunden sind. Zum anderen hat die Muttergesellschaft ein Interesse daran, ihrerseits die im Zusammenhang mit den außergerichtlichen Vertragsverhandlungen erlangten Informationen gemittelt über die Beklagten in das Verfahren einzubringen. Diese Interessen fanden in dem Vorschlag zum Abschluss eines Geheimhaltungsabkommens durch die Klägerin vom 03.06.2019 (Anlage F1) keinen unmittelbaren Niederschlag. Nachdem die Kammer den Parteien diese Erwägungen hingegen mitgeteilt hatte (vgl. Beschl. v. 07.4.2020, Ziff. 2., lit. c), letzter Abs., Bl. 393 GA, und Beschl. v. 15.04.2020, zu III., 2. Abs., Bl. 431 GA), zeigten sich nicht nur die Beklagten, sondern auch die Muttergesellschaft zur Unterzeichnung eines Geheimhaltungsabkommens bereit. Diese Umstände sprechen in ihrer Gesamtheit dagegen, dass es der Muttergesellschaft zuvorderst um die Verzögerung der Vertragsverhandlungen geht. 455

VII. 456

Da die Beklagten zur Benutzung der patentgemäßen Lehre nicht berechtigt waren, sie hinsichtlich der Auskunfts-, Schadensersatz- und Rückrufansprüche, die sich auf einen Zeitraum vor XXXXXXXXXXXXX einschließlich und mobile Endgeräte XXXXX XXXXXXXXXXXX

Rechtsfolgen:

1. 458

Der Klägerin steht derzeit kein Anspruch auf Unterlassung der klagepatentverletzenden Benutzungshandlungen sowie auf Rückruf und Vernichtung zu, weil sich die Beklagten erfolgreich auf den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand berufen haben. 459

2. 460

Der Klägerin steht gegen die Beklagte dem Grunde nach ein Schadensersatzanspruch gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 139 Abs. 2 PatG im tenorierten Umfang zu. 461

a) 462

Als Fachunternehmen hätte es den Beklagten oblegen, zu prüfen, ob die angebotenen und gelieferten Produkte klagepatentverletzend sind. Indem sie eine entsprechende Überprüfung unterließen, haben die Beklagten die im Verkehr erforderliche Sorgfalt missachtet, § 276 Abs. 2 BGB. 463

b) 464

Die Schadensersatzpflicht kann hier auch unbeschadet dessen festgestellt werden, ob der Schadensersatzanspruch der Höhe nach deshalb auf eine FRAND-gemäße Lizenzgebühr beschränkt ist, weil die Beklagten die ihnen obliegenden Anforderungen an das vom EuGH aufgestellte FRAND-Procedere erfüllt haben. 465

Der Schadensersatzanspruch dem Grunde nach verlangt lediglich die Wahrscheinlichkeit irgendeines Schadens (OLG Düsseldorf, GRUR-RS 2019, 6087, Rn. 227 – Improving Handovers). Ein solcher besteht vorliegend auch dann, wenn – was Prüfungsgegenstand eines etwaige Höheverfahrens wäre – der Schadensersatzanspruch auf die Zahlung einer FRAND-gemäßen Lizenzgebühr zu beschränken ist (a.a.O.). 466

c) 467

Die Klägerin hat an der begehrten Feststellung auch das erforderliche rechtliche Interesse im Sinne von § 256 Abs. 1 ZPO. Die Entstehung eines Schadens auf Seiten der Klägerin ist hinreichend wahrscheinlich. Eine Bezifferung dieses Schadens ist ihr nicht möglich, weil sie ohne Verschulden über die Informationen, die sie mit dem Klageantrag Ziff. I. 4. begehrt, in Unkenntnis ist. 468

3. 469

Der Auskunftsanspruch nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. § 140b PatG (Antrag Ziff. I. 3.) bleibt von dem hier erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand unberührt (so auch OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 28). Denn ein solcher setzt lediglich eine rechtswidrige Benutzungshandlung im Sinne von §§ 9 – 13 PatG voraus. Eine solche liegt hier vor. Tatsachen, die die Auskunftserteilung unverhältnismäßig im Sinne von § 140b Abs. 4 PatG erscheinen lassen, sind nicht vorgetragen. 470

4. 471

472

Soweit die Klägerin mit ihrem Antrag nach Ziffer I. 4. Rechnungslegung begehrt, steht ihr dieser Anspruch lediglich in dem aus dem Tenor erkennbaren Umfang gem. Art. 64 Abs. 1 EPÜ i. V. m. §§ 242, 259 BGB zu, damit sie in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist auf die tenorierten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt. Die Beklagten werden durch die von ihr verlangte Auskunft auch nicht erkennbar unzumutbar belastet.

Der Auskunftsanspruch aus §§ 242, 259 BGB umfasst vorliegend aufgrund des erfolgreich erhobenen kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwands keine Angaben zu Kosten und Gewinn der Beklagten im Zusammenhang mit der Patentverletzung. Wenn der SEP-Inhaber für die Nutzung der patentgemäßen Lehre lediglich eine angemessene, FRAND-Bedingungen entsprechende Lizenzgebühr verlangen kann, gebietet es der Grundsatz von Treu und Glauben, auch die Verpflichtung zur Auskunft und Rechnungslegung auf die zur Berechnung dieser FRAND-Lizenzgebühr erforderlichen Angaben zu beschränken (OLG Düsseldorf, ebd., Rn. 230 – Improving Handovers; a. A. LG Mannheim, GRUR 2018, 864, Rn.110 – Funkstation). 473

VIII. 474

Die Beklagten sind nicht berechtigt, die Lehre des Klagepatents aufgrund einer (Unter-)Lizenz zu benutzen. 475

1. 476

Die Beklagten können sich zur Rechtfertigung ihrer Benutzungshandlungen nicht mit Erfolg auf eine von XXXXX gegenüber XXX und deren Tochtergesellschaften eingeräumte (Unter-)Lizenz am Klagepatent berufen. Denn XXXXX, das eine Lizenzam Klagepatent hielt, war allenfalls berechtigt, solchen Tochtergesellschaften (Unter-)Lizenzen zu erteilen, an denen XXXX mehr als XX % der Anteile hielt. XXXXX war an XXX aber nur zu XX % beteiligt. Im Übrigen handelte XXX mit der Klägerin lediglich eine Lizenz für Patente in Bezug auf den GSM/GPRS-Standard aus. Das den UMTS-Standard betreffende Klagpatent blieb davon unberührt. 477

2. 478

Soweit sich die Beklagten zu Beginn des Rechtsstreits auf ein zwischen der Klägerin und der XXXXXXXXXX unter dem XXXXXXXXXXXXXX geschlossenes XXXXXXXXXX, die dazu gehörigen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX und XXXXXXXXX XXXX sowie ein XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berufen, war die Berechtigung zur Benutzung des Klagepatents zeitlich bis zum 31. Dezember 2013 beschränkt. Mit der Klage macht die Klägerin jedoch zu Recht nur noch Ansprüche für die Zeit danach, nämlich seit dem 1. Januar 2014 geltend. 479

IX. 480

Die Beklagten sind nicht berechtigt, die Leistung infolge Verjährung gemäß § 214 BGB zu verweigern. Die Verjährung der geltend gemachten Ansprüche ist bislang nicht eingetreten. 481

Die Verjährungsfrist für die im Jahr 2014 entstandenen Ansprüche – frühere Ansprüche werden nicht geltend gemacht – begann frühestens mit Ablauf des Jahres 2014. Denn gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden 482

Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.

Da die regelmäßige Verjährungsfrist gemäß § 195 BGB drei Jahre beträgt, endete die Verjährungsfrist für die im Jahr 2014 entstandenen Ansprüche frühestens mit dem Ende des Jahr 2017. Allerdings ist gemäß § 208 BGB jedenfalls die Zeit von Mitte 2015 bis Oktober 2016 nicht in die Verjährungsfrist einzurechnen, weil in diesem Zeitraum die Verjährung aufgrund von schwebenden Verhandlungen zwischen den Parteien gemäß § 203 BGB gehemmt war. Dann aber konnte die Verjährungsfrist für die zuerst entstandenen Ansprüche aus dem Jahr 2014 nicht vor Ende des Jahres 2018 ablaufen. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Klage erhoben und aufgrund dessen die Verjährung gemäß § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB erneutgehemmt. Die Verjährungsfrist ist bislang noch nicht abgelaufen. Dies gilt erst Recht für die nach dem Jahr 2014 entstandenen Ansprüche. 483

C 484

Für eine Aussetzung der Verhandlung besteht keine Veranlassung. 485

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug; GRUR 2014, 1237, 1238 – Zugriffsrechte) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines zeitlich beschränkten Patents Vorrang gebührt. Eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens kommt daher nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit (hinreichender) Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist (vgl. BGH GRUR 2014, 1237, 1238 – Zugriffsrechte). Eine solche Wahrscheinlichkeit kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht keine Veranlassung zur Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits. 486

I. 487

Es ist nicht wahrscheinlich, dass der Gegenstand des Klagepatentanspruchs 6 auf einer unzulässigen Erweiterung beruht und das Klagepatent insoweit vernichtet wird. 488

Zur Feststellung einer unzulässigen Erweiterung ist der Gegenstand des erteilten Patents mit dem Inhalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen zu vergleichen. Der Gegenstand des Patents wird durch die technische Lehre des jeweiligen Patentanspruchs bestimmt, wobei Beschreibung und Zeichnungen lediglich zur Auslegung heranzuziehen sind. Demgegenüber ist der Inhalt der ursprünglichen Anmeldung dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen zu entnehmen, ohne ihn auf die angemeldeten Ansprüche zu beschränken. Demnach gehört 489

zum Inhalt der ursprünglichen Anmeldung das, was der Fachmann als zur angemeldeten Erfindung gehörig entnehmen kann (vgl. zu Vorstehendem Benkard/Rogge, PatG 11. Aufl.: § 21 PatG Rn 30 m.w.N.).

Die Beklagten haben zwar zutreffend darauf hingewiesen, dass die mit der Patentanmeldung (Anlage B 5/2) ursprünglich eingereichten Ansprüche lediglich Verfahren zum Gegenstand hatten und keine Vorrichtung in Form einer Codiereinrichtung. Eine Codiereinrichtung im Sinne von Anspruch 6 in der erteilten Fassung wird jedoch in der Beschreibung der Patentanmeldung im Zusammenhang mit der Darstellung der Figur 1 offenbart. Zur Figur 1 wird ausgeführt, sie zeige ein vereinfachtes Blockschaltbild einer Anordnung zum Codieren, Punktieren und Abbilden von TFCI-Bits auf einen im „Compressed Mode“ zu sendenden UMTS-Rahmen (S. 6 der Anlage B 5/2). Ein (32/10)-Codierer 1 codiert uncodierte TFCI-Bits als ein 32 Bit langes TFCI-Codewort. Durch eine Punktiereinheit 2 werden die 32 TFCI-Bits auf 30 TFCI-Bits gekürzt, die dann von einer Einheit 3 im „Normal Mode“ oder im „Compressed Mode“ den einzelnen Zeitschlitzen oder Slots eines UMTS-Rahmens zugewiesen werden (S. 7 der Anlage B 5/2). Wie die Zuweisung im Einzelnen erfolgen kann, wird im weiteren Verlauf der Patentanmeldung und in den Verfahrensansprüchen beschrieben. Im Hinblick auf den Einwand der unzulässigen Erweiterung ist entscheidend, dass trotz der ähnlichen Begrifflichkeit nicht der in der Patentanmeldung genannte (32,10)-Codierer 1 der Codiereinrichtung im Sinne des Klagepatentanspruchs 6 entspricht, sondern die Einheit 3, weil sie die Abbildung der TFCI-Bits auf den UMTS-Rahmen vornimmt. Mehr verlangt auch Anspruch 6 des Klagepatents in der erteilten Fassung nicht. Insbesondere kann aus dem Begriff der Codiereinrichtung in Anspruch 6 nicht mit Erfolg hergeleitet werden, dass vor der Abbildung der TFCI-Bits auf den UMTS-Rahmen zwingend eine Codierung von ursprünglichen TFCI-Bits in ein TFCI-Codewort stattgefunden haben muss. Gegenstand des Klagepatentanspruchs 6 ist eine Codierreinrichtung lediglich zum Abbilden von Formatkennungsbits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen. Auch die weiteren Merkmale des Anspruchs betreffen lediglich den Abbildevorgang. Jede Vorrichtung, die diesen Abbildevorgang leistet, stellt eine Codiereinrichtung im Sinne des Klagepatents dar. Ein Codiervorgang, der dem anspruchsgemäßen Abbildevorgang vorausgeht oder sonst wie darüber hinausgeht, ist nicht erforderlich. 490

II. 491

Die Lehre von Anspruch 6 des Klagepatents wird durch die EP X A2 (Anlage B5/9) nicht neuheitsschädlich vorweggenommen. Die Entgegenhaltung stellt im Hinblick auf Klagepatentanspruch 6 keinen Stand der Technik im Sinne von Art. 54 Abs. 2 und 3 EPÜ dar. 492

Gemäß Art. 54 Abs. 1 EPÜ gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet gemäß Art. 54 Abs. 2 EPÜ alles, was vor dem Anmeldetag der europäischen Patentanmeldung der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. Gemäß Art. 89 EPÜ gilt hingegen im Sinne von Art. 54 Abs. 2 EPÜ der Prioritätstag der Anmeldung als Anmeldetag. Allerdings umfasst das Prioritätsrecht nur die Merkmale der europäischen Patentanmeldung, die in der Anmeldung oder den Anmeldungen enthalten sind, deren Priorität in Anspruch genommen worden ist, Art. 88 Abs. 3 EPÜ. 493

Das ist hinsichtlich der Anmeldung des Klagepatents in Bezug auf die Lehre des Klagepatentanspruchs 6 der Fall. Insbesondere offenbart die Prioritätsanmeldung (Anlage B 5/3) nicht nur ein Verfahren, sondern auch eine Codiereinrichtung zum Abbilden von Formatkennungsbits auf einen in einem Komprimiermodus zu sendenden Rahmen im Sinne von Anspruch 6 in der erteilten Fassung. Die Prioritätsanmeldung beschreibt wie auch die 494

Anmeldung des Klagepatents (Anlage B 5/2) im Zusammenhang mit der Darstellung der Figur 1 eine Anordnung zum Codieren, Punktieren und Abbilden von TFCI-Bits (vgl. S. 7 f. der Anlage B 5/2). Als Codiereinrichtung im Sinne von Anspruch 6 in der erteilten Fassung kann ohne weiteres die der Abbildung der TFCI-Bits auf den UMTS-Rahmen dienende Einheit 3 angesehen werden. Auf die Erwägungen im Zusammenhang mit dem Einwand der unzulässigen Erweiterung kann insofern uneingeschränkt verwiesen werden. Denn die Ausführungen der Prioritätsanmeldung sind in diesem Zusammenhang wortgleich mit der Patentanmeldung (dort S. 6 f. der Anlage B 5/2). Auch wenn Figur 1 nur einBlockschaltbild darstellt, werden in der Beschreibung der Prioritätsanmeldung ebenso wie in der Patentanmeldung die einzelnen Komponenten einer Anordnung zum Abbilden von TFCI-Bits auf einen UMTS-Rahmen dargestellt, darunter die Einheit 3 (S. 8 der Anlage B 5/3 bzw. S. 6 f. der Anlage B 5/2). Da es nach der Lehre von Anspruch 6 in der erteilten Fassung nicht auf eine über die Abbildung von Formatkennungsbits auf einen komprimierten Rahmen hinausgehende Codierung ankommt, ist sowohl die weitere Offenbarung eines (32,10)-Codierers oder anderer Komponenten der Anordnung als auch die der Reed-Muller-Codierung im Zusammenhang mit der Figur 1 der Prioritätsanmeldung unbeachtlich. Eine Zwischenverallgemeinerung liegt nicht vor. Denn die Einheit 3 kann ohne weiteres als funktional selbstständige Einheit verstanden werden, die das in der Prioritätsanmeldung im Übrigen offenbarte Verfahren anwenden kann.

Die Entgegenhaltung EP 2 293 480 A2 gehört nicht zum Stand der Technik. Denn sie wurde erst nach dem 24. November 1999 angemeldet. Maßgeblich ist für sie der Anmeldetag vom 15. September 2000. Die von der EP X A2 in Anspruch genommene Priorität X kann keinen früheren Zeitrang begründen, da sie vom 23. Februar 2000 stammt und damit bereits hinter dem Prioritätsdatum des Klagepatents liegt. Aber auch die Priorität US X (Anlage KAP 18) kann für die EP X A2 keinen früheren Zeitrang begründen, weil sie nicht alle Merkmale der europäischen Patentanmeldung umfasst, die die Neuheitsschädlichkeit der EP X A2 gegenüber dem Klagepatent begründen sollen. Es ist unstreitig, dass die US X nicht das Merkmal 6.5 offenbart, wonach die unmittelbar der Übertragungslücke folgenden Formatkennungsbits in umgekehrter Reihenfolge wiederholt abgebildet werden, um die nach dem ersten Abbilden noch unbelegten Formatkennungsstellen des komprimierten Rahmens mit einem Formatkennungsbit zu belegen. Dieses Merkmal ist erstmals in der Entgegenhaltung EP X A2 selbst enthalten (siehe Abs. [0083] der Anlage B 5/9). 495

III. 496

Schließlich bestehen auch noch vernünftige Gründe für die Annahme, dass die Lehre des Klagepatents ausgehend von dem Verbesserungsvorschlag TSGR1#7bis(99)e86 (Anlage B 5/10) nicht nahegelegt war. 497

Bei der Entgegenhaltung TSGR1#7bis(99)e86 handelt es sich um einen Verbesserungsvorschlag für den Compressed Mode im UMTS. Unstreitig werden alle Merkmale der Klagepatentansprüche bis auf das Merkmal 5 offenbart. Der Auffassung der Beklagten, die Abbildung der der Übertragungslücke unmittelbar folgenden TFCI-Bits in umgekehrter Reihenfolge habe für den Fachmann auf der Hand gelegen, vermag die Kammer nicht zu folgen. Zwar wird bereits in dem Verbesserungsvorschlag darauf hingewiesen, dass Zeitschlitze direkt nach der Übertragungslücke unter einer etwas schlechteren Leistungssteuerung leiden. Es kann aber gleichwohl nicht angenommen werden, dass damit dem Fachmann ein Weg zur patentgemäßen Lehre gewiesen war. Auch aus der Patentschrift ergibt sich, dass die schlechtere Leistungssteuerung in den Zeitschlitzen unmittelbar nach der Übertragungslücke im Stand der Technik bekannt war. Als 498

Reaktion auf dieses Problem sollten nach dem Stand der Technik die der Übertragungslücke unmittelbar folgenden TFCI-Bits wiederholt werden (vgl. Abs. [0011]). Dem Prüfer im Erteilungsverfahren war all dies bekannt, gleichwohl wurde das Patent erteilt. Es besteht kein Grund, sich über diese sachverständige technische Wertung hinwegzusetzen. Tatsächlich schien das technische Problem im Stand der Technik mit der Wiederholung der der Übertragungslücke folgenden TFCI-Bits auch gelöst. Es fehlt insofern an einem Anstoß, Hinweis oder Anlass, derer es in der Regel über die Erkennbarkeit des technischen Problems hinaus bedarf (BGH, Urt. v. 30.04.2009, Xa ZR 92/05 – Betrieb einer Si-cherheitseinrichtung; Urt. v. 08.12.2009, X ZR 65/05 – einteilige Öse), die vorgeschlagene Lösung im Detail weiter zu verbessern. Auch der entgegengehaltene Verbesserungsvorschlag sieht keine weiter gehenden Maßnahmen vor.

Es kann auch nicht davon ausgegangen werden, eine Umordnung von Bits sei eine ganz übliche Maßnahme, die der Fachmann ohne weiteren Anlass aufgrund stetiger Verbesserungsbemühungen vornehme. Der Verweis auf die US X (Anlage B 5/11) und weitere Entgegenhaltungen (Anlagen B 5/12 bis B 5/16) greift insofern nicht durch. Der Fachmann hatte keinen Anlass, diese Entgegenhaltungen, die durchweg aus anderen technischen Gebieten stammen, mit dem Verbesserungsvorschlag TSGR1#7bis(99)e86 zu kombinieren. Dem steht auch nicht der Grundsatz entgegen, wonach Veranlassung zur Heranziehung einer technischen Lösung, die als ein generelles, für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehört, bereits dann bestehen kann, wenn es für die Anwendung dieserLösung zwar kein konkretes Vorbild gibt, die Nutzung ihrer Funktionalität in dem betreffenden Zusammenhang sich aber als objektiv zweckmäßig darstellt und keine besonderen Umstände festzustellen sind, die eine Anwendung als nicht möglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGH GRUR 2014, 647 Farbversorgungssystem; Mitt. 2018, 21 Rn. 113 – Spinfrequenz). Es bestehen schon Zweifel, ob die Umkehrung der Übertragungsreihenfolge tatsächlich ein gängiges, in vielen Fällen anwendbares Mittel zur Reduzierung der Fehlerrate bei der Datenübertragung darstellt. Die Klägerin hat insofern bestritten, dass die Entgegenhaltungen B 5/15 und B 5/16 Stand der Technik bilden. In den Entgegenhaltungen B 5/12 bis B 5/14 werden zwar Bits in umgekehrter Reihenfolge übertragen. Ob dies aber in allen Fällen der Reduzierung von Übertragungsfehlern dient, ist nicht vorgetragen. Vielmehr besteht der Eindruck, dass die umgekehrte Übertragungsreihenfolge lediglich die Funktion hat, die Daten schneller verarbeiten zu können (Entgegenhaltungen B 5/12 und B 5/13) oder Datenfolgen besser unterscheiden zu können (Entgegenhaltung B 5/14). Allein aus der Entgegenhaltung B5/11 kann aber nicht hergeleitet werden, dass der Fachmann die Umkehrung der TFCI-Bits als allgemein bekannte und auch im Fall der TSGR1#7bis(99)e86 zweckmäßige Lösung angesehen hat. 499

D 500

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1 S. 1, 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. 501

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 S. 1 und 2 ZPO. Dem von den Beklagten hilfsweise geltend gemachten Vollstreckungsschutz-antrag war nicht stattzugeben, da sie die Voraussetzungen des § 712 Abs. 1 ZPO weder dargelegt, noch gemäß § 714 Abs. 2 ZPO glaubhaft gemacht haben. 502

Die Sicherheitsleistung für die vorläufige Vollstreckung war nicht höher als 135.000,00 EUR festzusetzen. Grundsätzlich gilt, dass die Vollstreckungsschäden – und damit die Sicherheitsleistung – dem Streitwert entsprechen. Wird dem Klageantrag nur teilweise 503

stattgegeben, wird die Sicherheitsleistung regelmäßig in einer Höhe festgesetzt, die dem Anteil des Obsiegens am Gesamtstreitwert entspricht. Eine höhere Sicherheitsleistung kann allenfalls dann seitens der Kammer angeordnet werden, wenn die Beklagten konkrete Anhaltspunkte dafür vortragen, dass eine in Höhe des Streitwerts festgesetzte Sicherheit den drohenden Vollstreckungsschaden nicht vollständig abdecken wird (vgl. OLG Düsseldorf,GRUR-RR 2012, 304 ff – Höhe des Vollstreckungsschadens). Vorliegend haben die Beklagten lediglich für den Fall der Verurteilung zur Unterlassung beantragt, die Sicherheitsleistung auf 10.000.000,00 EUR festzusetzen. Da die Beklagten jedoch weder zur Unterlassung verpflichtet sind, noch vorgetragen haben, welche Vollstreckungsschäden im Fall der Vollstreckung der Verurteilung zur Auskunft und Rechnungslegung drohen, war die Sicherheitsleistung in der auch sonst üblichen Höhe festzusetzen.

Streitwert: 675.000,00 EUR, wovon 67.500,00 EUR auf den Antrag auf Feststellung der gesamtschuldnerischen Verpflichtung zum Schadensersatz entfallen. 504

Justiz NRW
Rechtsprechungsdatenbank ONLINE